

DIGESTO

RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

MANUAL DE ESTUDIO · NIVEL EXAMEN DE GRADO

Elaborado por **Laura Schultz Solano**

Síntesis propia en base a los apuntes de Cristián Boetsch Gillet y el Tratado de Enrique Barros Bourie, con jurisprudencia seleccionada y comparaciones doctrinales · Versión Junio 2026

Índice

1. Concepto de responsabilidad extracontractual
2. Fundamentos, principios y evolución histórica
3. Diferencias y relación con la responsabilidad penal
4. Diferencias y relación con la responsabilidad contractual
5. Requisitos de la responsabilidad extracontractual
 - a. Acción u omisión
 - b. El daño
 - c. Factores de atribución y antijuridicidad
 - d. Causalidad
6. Presunciones de responsabilidad
 - a. Consideraciones generales
 - b. Presunción por el hecho propio (art. 2329)
 - c. Presunción por el hecho ajeno (arts. 2320-2322)
 - d. Presunción por el hecho de las cosas (arts. 2323-2328)
7. Cláusulas modificatorias o eximentes de responsabilidad
 - a. Concepto y admisibilidad
 - b. Clases de cláusulas
 - c. Límites de validez
 - d. Distinciones necesarias
8. El problema de la concurrencia de responsabilidades
 - a. Planteamiento del problema
 - b. Por qué importa la calificación
 - c. Las posiciones doctrinales
 - d. Cúmulo de responsabilidades y de indemnizaciones
9. La acción de responsabilidad extracontractual
 - a. Las acciones que nacen del daño
 - b. Legitimación activa: los titulares de la acción
 - c. Legitimación pasiva: los obligados a responder
 - d. La solidaridad (art. 2317)
 - e. Tribunal competente y procedimiento
 - f. Extinción de la acción y prescripción

1. CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

1.1. La noción general de responsabilidad civil

En su acepción más amplia, la responsabilidad alude a la necesidad efectiva, o eventual, en que se encuentra una persona de hacerse cargo de las consecuencias gravosas de un acto que se le atribuye como propio. En el campo del derecho civil, esa noción se traduce en la obligación de reparar el daño causado a otro: una persona es responsable cuando está sujeta al deber de indemnizar los perjuicios sufridos por una víctima.

La doctrina chilena, siguiendo a ALESSANDRI, ha entendido la responsabilidad civil como "la obligación que pesa sobre una persona de indemnizar el daño sufrido por otra". En idéntico sentido, DUCCI señalaba que "responsabilidad en su sentido más amplio es la obligación de satisfacer cualquier daño o perjuicio; es el estar sujeto a responder de alguna cosa o por alguna persona". Ambas definiciones destacan el componente central del instituto: la existencia de un daño y la consecuente obligación de repararlo mediante la indemnización de perjuicios.

La responsabilidad civil no tiene por objeto castigar a quien causa el daño, sino restablecer en el patrimonio de la víctima la situación que existía antes de que el perjuicio se produjera. En esto difiere radicalmente del sistema penal, cuya función sancionatoria trasciende la relación entre autor y víctima. El objeto de la acción de responsabilidad civil consiste, pues, en la reparación pecuniaria de ciertos daños, de manera que sus consecuencias patrimoniales sean soportadas definitivamente por quien los causó y no por quien los sufrió.

JURISPRUDENCIA — CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Corte Suprema, 6 de noviembre de 1972. "Por responsabilidad debe entenderse, en general, la obligación en que se coloca una persona para reparar adecuadamente todo daño o perjuicio causado." Este fallo —citado tanto por Barros como por Boetsch— constituye la definición jurisprudencial de referencia en la materia.

Corte Suprema, 29 de noviembre de 1968. La procedencia de las indemnizaciones "presupone la existencia de un perjuicio, menoscabo, disminución o pérdida para quien lo experimenta o sufre".

La pregunta central que plantea el derecho de la responsabilidad civil consiste en determinar los criterios según los cuales las consecuencias patrimoniales del daño sufrido por una persona deben radicarse en el patrimonio de otra, por medio de la indemnización de perjuicios; y, a contrario sensu, en qué casos dichas consecuencias deberán quedarse donde se producen. Esta es, en definitiva, la pregunta por los fundamentos de la atribución de responsabilidad.

1.2. La responsabilidad extracontractual: concepto y denominaciones

La responsabilidad civil reconoce dos grandes estatutos en el ordenamiento nacional: la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. La primera es la obligación del deudor de indemnizar al acreedor los perjuicios que le ha originado el incumplimiento, cumplimiento imperfecto o cumplimiento tardío de una obligación preexistente. La segunda, que es el objeto del presente manual, es la obligación en que se encuentra el autor de indemnizar los perjuicios que su hecho ilícito —delito o cuasidelito civil— ha ocasionado a la víctima, sin que entre ambos exista vínculo jurídico anterior alguno.

La responsabilidad extracontractual recibe también las denominaciones de responsabilidad *aquiliana* o *delictual*. El apelativo "aquiliana" proviene de la *Lex Aquilia de damno* dictada en Roma durante el siglo III a.C., primera consagración de un principio general de responsabilidad por daños causados con culpa a cosas ajenas; el término "delictual" hace referencia al delito o cuasidelito civil como fuente de la obligación indemnizatoria. En Chile, la doctrina y la jurisprudencia emplean indistintamente estas denominaciones.

Lo característico de la responsabilidad extracontractual, frente a la contractual, es que la obligación de indemnizar tiene un carácter *originario* o de primer grado: no supone la existencia de una relación jurídica previa entre la víctima y el autor del daño, sino que nace directamente del hecho ilícito. Su antecedente se encuentra en los deberes generales y recíprocos de conducta que las personas deben observar en sus encuentros espontáneos en el tráfico social. En materia contractual, en cambio, la responsabilidad tiene carácter *secundario* o de segundo grado, porque la obligación originaria es cumplir lo convenido, y la obligación de indemnizar surge únicamente cuando el deudor ha incumplido esa obligación principal.

Distinción fundamental: responsabilidad originaria vs. secundaria

En la responsabilidad extracontractual el vínculo obligatorio nace directamente del hecho ilícito (primer grado). En la contractual, el deber de indemnizar es consecuencia del incumplimiento de una obligación ya existente (segundo grado). Esta distinción explica buena parte de las diferencias de régimen entre ambos estatutos.

1.3. El hecho ilícito como fuente de obligaciones: delito y cuasidelito civil

El Código Civil chileno otorga a los delitos y cuasidelitos la categoría de fuentes de obligaciones. El artículo **1437** dispone que "las obligaciones nacen [...] ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos". A su turno, el artículo **2284** precisa: "Si el hecho es ilícito, y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito".

Conforme a estos preceptos, es posible definir el *delito civil* como el hecho ilícito cometido con intención de dañar que ha inferido injuria o daño a otra persona (arts. 1437, 2284 y 2314 del Código Civil). El *cuasidelito civil* es, en cambio, el hecho culpable cometido sin intención de dañar que ha producido daño a otro (arts. 1437, 2284 y 2314). Ambas figuras comparten los rasgos de ser hechos ilícitos y

causar daño; lo que los diferencia es el elemento subjetivo: el dolo en el delito, la culpa en el cuasidelito.

Esta distinción entre delito y cuasidelito civil tiene escasa relevancia práctica en el sistema de responsabilidad extracontractual, porque el Código Civil establece las mismas consecuencias para ambos: la obligación de indemnizar los perjuicios causados (art. 2314). La única diferencia de tratamiento legal relevante se presenta en materia de prescripción y en la aplicación del artículo 2317 sobre solidaridad. En consecuencia, tanto el autor doloso como el culposo quedan sujetos al mismo régimen indemnizatorio, a diferencia de lo que ocurre en materia penal, donde la distinción entre dolo y culpa tiene profunda incidencia en la pena.

El hecho ilícito es fuente de obligaciones porque da origen a una obligación que antes de él no existía: la de indemnizar los perjuicios causados. Esta responsabilidad nace al margen de la voluntad del autor: aunque haya actuado con dolo —con intención de causar daño—, el autor no ha querido adquirir una obligación; ha querido el daño, pero no convertirse en deudor de la reparación. Si hay solo culpa —negligencia o imprudencia—, no existe ni siquiera la intención de perjudicar, y con mayor razón no hay voluntad de obligarse.

1.4. Regulación legal

La responsabilidad extracontractual se encuentra regulada en el **Título XXXV del Libro IV del Código Civil**, artículos **2314** a **2334**, denominado "De los delitos y cuasidelitos". Este título contiene las normas fundamentales del sistema, desde la regla general de atribución de responsabilidad por culpa hasta las presunciones especiales y las reglas sobre pluralidad de autores.

El precepto central del sistema es el artículo **2314**: "El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito". A esta norma se suman otras de importancia cardinal: el artículo **2329**, que establece el principio de reparación integral de todo daño imputable a malicia o negligencia; y los artículos **2319** a **2328**, que regulan la capacidad delictual, la responsabilidad por el hecho ajeno y la responsabilidad por el hecho de las cosas.

Junto al Código Civil, numerosos estatutos legales especiales regulan hipótesis específicas de responsabilidad extracontractual, sometidas frecuentemente a regímenes de responsabilidad objetiva o estricta: la Ley N.º 18.290 (Tránsito), la Ley N.º 16.744 (accidentes del trabajo), la Ley N.º 18.490 (seguro obligatorio), la Ley N.º 19.300 (medio ambiente) y la normativa sobre aeronaves, daños nucleares y derrames de hidrocarburos, entre otras.

Dato de grado — Regulación y normas clave

Las normas del Título XXXV del Libro IV del Código Civil (arts. 2314-2334) constituyen el estatuto general y supletorio de responsabilidad extracontractual. Las normas de mayor relevancia para el examen de grado son:

- **Art. 1437:** fuentes de las obligaciones (delitos y cuasidelitos).
- **Art. 2284:** definición de delito y cuasidelito civil.
- **Art. 2314:** norma general de responsabilidad — obligación de indemnizar.
- **Art. 2319:** incapacidades delictuales.
- **Art. 2320:** responsabilidad por el hecho ajeno.
- **Art. 2329:** reparación integral del daño; presunción de culpa por actividades peligrosas.
- **Art. 2332:** prescripción de 4 años desde la perpetración del acto.

PAUSA — COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado la **Sección 1 — Concepto de responsabilidad extracontractual**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

2. FUNDAMENTOS, PRINCIPIOS Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA

2.1. El principio rector: *alterum non laedere*

El fundamento primero y más elemental de la responsabilidad extracontractual es el principio romano *alterum non laedere*: nadie tiene derecho a dañar injustificadamente a otro. Este principio expresa el límite básico que el ordenamiento impone a la libertad de actuación de los particulares: la libertad de obrar cesa donde comienza el derecho de los demás a no ser perjudicados sin justificación.

De este principio se derivan dos consecuencias simétricas. Por una parte, quien sufre un daño injusto tiene derecho a que el ordenamiento le proporcione una acción para obtener su reparación. Por otra parte, quien actúa respetando los deberes de cuidado generales no tiene por qué responder de los daños que su actividad lícita pueda ocasionar. En otros términos, la responsabilidad civil presupone necesariamente una calificación del daño: no todo daño es jurídicamente relevante, sino solo aquel que el ordenamiento considera injusto imputar a quien lo sufre.

El juez HOLMES sintetizó esto con precisión al sostener que "el principio general es que la pérdida de un accidente debe quedar donde caiga": cada persona corre con los riesgos que impone la vida en sociedad, salvo que concurra una razón jurídica para atribuir el costo del daño a un tercero. La responsabilidad civil es, precisamente, el estatuto que determina cuándo y en qué condiciones esa razón existe.

2.2. Modelos de atribución de responsabilidad civil

La pregunta esencial que plantea la responsabilidad civil es la de los criterios que determinan cuándo el costo del daño sufrido por una persona debe ser asumido por un tercero. El derecho comparado y el derecho nacional han desarrollado principalmente dos modelos de atribución, a los que se agrega, como complemento de naturaleza contractual, el sistema de seguros obligatorios.

a) Responsabilidad por culpa o negligencia

La responsabilidad por culpa o negligencia constituye el modelo más generalizado en el derecho moderno y, en el derecho nacional, la *regla general* aplicable a todos los casos no cubiertos por un estatuto especial. Conforme a este modelo, la razón para atribuir responsabilidad a un tercero reside en que el daño ha sido causado por su acción *culpable*, esto es, mediante la infracción de un deber de cuidado. Este deber puede estar establecido expresamente por la ley —como en la normativa de tránsito o medioambiental— o ser determinado por los jueces con posterioridad al hecho, recurriendo a la costumbre, a la práctica del sector de actividad o a criterios de razonabilidad.

A diferencia de lo que ocurre en el derecho penal, en el que el principio de tipicidad exige que la conducta sancionada se encuentre previamente descrita por la ley, en el ámbito civil la ilicitud de la conducta puede ser establecida judicialmente, sin texto legal previo que la defina. Esta es una diferencia radical entre ambos sistemas de responsabilidad. La enorme variedad de la conducta humana y la multiplicidad de riesgos que impone la vida en sociedad hacen imposible que la ley pueda definir con exhaustividad todos los deberes de cuidado exigibles; de ahí que la mayor parte de ellos quede entregada a la apreciación prudencial del juez.

Los elementos del régimen general de responsabilidad por culpa son: (a) el hecho voluntario —acción u omisión—; (b) la culpa o el dolo; (c) el daño; y (d) la relación de causalidad entre la conducta culpable y el daño. Los artículos **2284**, **2314** y **2329** del Código Civil son sus pilares normativos fundamentales.

b) Responsabilidad estricta u objetiva

A diferencia del modelo por culpa, la responsabilidad estricta u objetiva establece la obligación de indemnizar todo daño producido en el ejercicio de cierta actividad, con independencia de la diligencia empleada por quien la realiza. El fundamento de este modelo no es la conducta reprochable del autor, sino el riesgo creado por su actividad. En términos generales, basta con que el daño se verifique dentro del ámbito de la actividad sujeta a este régimen y que exista relación de causalidad entre esa actividad y el daño, sin necesidad de calificar la negligencia del autor.

La responsabilidad estricta es un régimen *especial y de derecho estricto*, que opera únicamente respecto de los ámbitos de conducta o tipos de riesgo previamente definidos por el legislador. Su fuente es siempre la ley. En el derecho nacional están sometidos a responsabilidad objetiva, entre otros: el propietario del vehículo motorizado en los accidentes de tránsito con resultado lesivo (con la particularidad de exigir culpa del conductor); el explotador de aeronaves; el causante de derrames de hidrocarburos; y el operador de instalaciones nucleares. Dentro del propio Código Civil, los artículos **2327** (daño causado por animal fiero sin utilidad para el predio) y **2328** inciso primero (cosa que cae o se arroja de un edificio) configuran también hipótesis de responsabilidad estricta, pues no admiten la prueba de diligencia como exculpación.

La responsabilidad estricta presenta cierta analogía con las obligaciones de garantía del derecho contractual —como el saneamiento de la evicción en la compraventa—, en cuanto establece un deber general de garantía que asegura a las potenciales víctimas la reparación de todo daño causado en el ámbito de la actividad riesgosa. Resulta imposible, sin embargo, extender este modelo a la generalidad de los casos, pues convertiría en ilícita cualquier actividad susceptible de causar daño —como la competencia empresarial o la libre expresión de opiniones— y transformaría radicalmente la forma en que los individuos se relacionan en sociedad.

c) El seguro privado obligatorio

El seguro no es propiamente un sistema de atribución de responsabilidad civil, sino una técnica de distribución del riesgo. En virtud del seguro obligatorio, quien desarrolla una actividad susceptible de causar daños —circular en automóvil, explotar una empresa, etc.— está legalmente obligado a contratar un seguro de responsabilidad que garantice la indemnización de las víctimas. El costo de los accidentes es así distribuido entre todos los candidatos a víctima mediante un aumento del precio del bien o servicio correspondiente, que incluye la prima del seguro.

En el derecho chileno, los principales sistemas de seguro obligatorio son el seguro automotriz obligatorio (Ley N.º 18.490) y el seguro por accidentes del trabajo (Ley N.º 16.744). Ambos operan con independencia del juicio de culpabilidad, garantizando la compensación de la víctima con anterioridad a la determinación de responsabilidades. En presencia de culpa del causante del daño, el asegurador que pagó se subroga legalmente en las acciones que corresponden a la víctima (art. 553 del Código de Comercio), permitiéndole recuperar lo pagado del autor material del daño.

2.3. Fines de la responsabilidad extracontractual

Los fines de la responsabilidad civil permiten comprender las razones que justifican la existencia de un determinado régimen de atribución de responsabilidad y orienta la interpretación de sus reglas. La doctrina reconoce cuatro funciones principales, que en la práctica concurren y se complementan.

a) Función de reparación del daño

La función primordial y más evidente de la responsabilidad extracontractual es la reparación del daño causado. La obligación de indemnizar tiene por objeto dejar a la víctima indemne, esto es, restituirla —en la medida en que el dinero lo permite— a la situación en que se habría encontrado de no haber sufrido el perjuicio. Esta función se expresa en el principio de reparación integral, consagrado en el artículo **2329** del Código Civil, según el cual "por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta".

Debe advertirse, con todo, que la compensación de las víctimas no es un fin que el derecho de la responsabilidad civil persiga *a todo evento*. La responsabilidad civil se refiere por igual a las condiciones para dar lugar a la obligación indemnizatoria y al fracaso de las pretensiones reparatorias cuando dichas condiciones no se cumplen. Así lo señala BARROS: "La compensación de la víctima sólo tiene lugar cuando se cumplen las condiciones de la responsabilidad". De lo contrario, la acción de responsabilidad se confundiría con el seguro social.

Corte de Apelaciones de Santiago, 1 de septiembre de 2003. "Nuestro derecho consagra el principio de la reparación integral o completa del daño, aplicable en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual."

Corte de Apelaciones de Santiago, 10 de julio de 2002. "La reparación del daño es el principal efecto que nuestro legislador asigna a la responsabilidad delictual o cuasidelictual."

b) Función de garantía de la libertad de actuar

La responsabilidad extracontractual sirve también para delimitar la esfera de libertad que el ordenamiento reconoce a cada persona. El principio *alterum non laedere* implica que nadie tiene derecho a actuar si con ello perjudica a alguien que no está obligado a soportar ese daño. Pero, al mismo tiempo, define negativamente el espacio de libre actuación: quien no infringe deberes de cuidado ajenos puede actuar con plena libertad, aun cuando ello cause daños a terceros (como sucede con el competidor que arruina el negocio de otro respetando las reglas del mercado).

En este sentido, BOETSCH observa que la responsabilidad extracontractual "es un elemento de garantía de la persona que permite saber a priori cuáles eventos pueden serle imputados a quien actúa y consiente a la persona una libre elección de sus propios comportamientos". El sistema de responsabilidad opera, pues, como un mecanismo de demarcación de esferas de acción.

c) Función preventiva

Desde la perspectiva del análisis económico del derecho, el fin de las reglas de responsabilidad civil es la prevención óptima de accidentes. El establecimiento de la obligación de indemnizar opera como desincentivo a las conductas negligentes, induciendo a los actores sociales a internalizar los costos de los daños que su actividad puede generar. De este modo, el sistema de responsabilidad actúa como un mecanismo descentralizado de control: es la propia víctima —con la amenaza de su acción indemnizatoria— quien vela por que el potencial causante del daño observe los niveles óptimos de cuidado.

La doctrina económica ha debatido extensamente si la responsabilidad por culpa o la responsabilidad objetiva es el régimen más eficiente desde el punto de vista de la prevención. POSNER defiende la responsabilidad por culpa, argumentando que el nivel de cuidado exigible reconduce al óptimo social. CALABRESI, en cambio, es partidario de la responsabilidad objetiva, pues obliga a quien genera el riesgo a internalizar el costo total de los accidentes. La doctrina más reciente tiende a sostener que en principio es indiferente uno u otro régimen, y que lo decisivo son las características del riesgo de que se trate.

d) Función de justicia correctiva

Desde la perspectiva normativa —que BARROS considera la más fundamental— la responsabilidad civil tiene por objeto dar una solución justa a la relación entre el autor del daño y la víctima. La noción de *justicia correctiva*, de origen aristotélico, atiende a la relación bilateral entre ambas partes: quien comete un injusto se apro-

pia de lo que no le pertenece, y la justicia exige restablecer la igualdad perturbada, obligando al autor a reparar el daño causado.

La justicia correctiva ofrece una comprensión *interna* del derecho de la responsabilidad civil: en lugar de tratar la responsabilidad como un instrumento de políticas públicas, la concibe como la expresión de la relación normativa que nace entre la víctima y el autor del daño. Esta correlatividad entre el deber del causante y el derecho de la víctima da unidad de sentido a los elementos del sistema: el hecho ilícito, el daño y el derecho a la reparación se articulan como momentos de una misma relación de justicia entre personas iguales.

e) Función distributiva y función punitiva

La *justicia distributiva* atiende a la perspectiva social: la distribución equitativa del costo de los accidentes entre todos quienes están expuestos al mismo riesgo. Desde esta perspectiva, la solidaridad con las víctimas exige corregir la aleatoriedad con que los accidentes se distribuyen, haciendo que el costo no recaiga solo sobre quien tuvo la desgracia de ser dañado. Los seguros obligatorios y los regímenes de responsabilidad objetiva son los instrumentos más directamente orientados a este fin distributivo.

La *función punitiva*, por su parte, está presente en algunos sistemas —especialmente en el derecho de daños angloamericano (*Tort Law*)—, que reconocen los llamados daños punitivos (*punitive damages*): indemnizaciones que superan el monto del daño efectivo y tienen por objeto castigar al responsable cuando su conducta ha sido particularmente grave o maliciosa. En los sistemas de derecho civil continental, incluido el chileno, esta función es en principio ajena a la responsabilidad civil, aunque la jurisprudencia nacional tiende a incorporar consideraciones punitivas implícitas en la valoración del daño moral, al ponderar la gravedad del ilícito y la capacidad económica del demandado.

Dato de grado — Las cuatro funciones de la responsabilidad extracontractual (Boetsch)

Boetsch Gillet distingue cuatro funciones de la responsabilidad extracontractual: (1) **reparación del daño** —función primordial—; (2) **garantía de la libertad de actuar** —delimita la esfera de licitud—; (3) **prevención** —desincentivo a conductas dañosas—; y (4) **función punitiva** —presente en el derecho de daños angloamericano (*Tort Law*), ausente en principio en el sistema chileno—. Esta clasificación es más detallada que la bipartición de Barros (prevención + justicia) y puede ser útil para respuestas precisas en el examen.

2.4. Evolución histórica de la responsabilidad civil

a) De la venganza privada a los mecanismos institucionales

En las primeras culturas, el régimen dominante de responsabilidad parece haber sido la responsabilidad estricta. La venganza privada tiene lugar por el solo hecho de haberse causado un daño, sin indagar si el resultado podía atribuirse a culpa del autor. En ausencia de instituciones políticas y judiciales, la retribución era tarea del clan al que pertenecía la víctima. Los primeros atisbos de derecho —aún antes de la existencia de un órgano jurisdiccional— consisten precisamente en procedi-

mientos para neutralizar la venganza privada mediante instancias de apaciguamiento y mediación.

Las primeras codificaciones conocidas mantienen esta estructura. El Código de Hammurabi (siglo XVII a.C.) establece con nitidez la ley del talión, sin perjuicio de contemplar también compensaciones en dinero para daños no personales. Similar fue la situación en Roma: la Ley de las XII Tablas (siglo V a.C.) establecía asimismo la ley del talión, y el derecho romano posterior no se desprendió del todo de la función punitiva de la responsabilidad: las sanciones en dinero por valores de dos o cuatro veces el bien destruido tenían un carácter esencialmente punitivo. Fue el derecho francés el que finalmente desarrolló el concepto de la responsabilidad como obligación de indemnizar los perjuicios efectivamente causados, que luego se generalizó en las doctrinas modernas del derecho natural.

b) Del casuismo hacia los principios generales

La evolución de la responsabilidad civil en Roma no concluyó en la formulación de un principio general de responsabilidad por negligencia. La *Lex Aquilia* (siglo III a.C.) solo consideró ilícitos específicos —la muerte o lesiones a un esclavo, o el daño de una cosa ajena—. En las compilaciones bizantinas se construyó la figura de las obligaciones que nacen *quasi ex delicto*, pero también con carácter casuístico. Fue únicamente en el pensamiento moderno, bajo la influencia del derecho canónico —con su inclinación a expandir el fundamento moral del derecho privado— y de la escuela del derecho natural, que se desarrolló una regla general de responsabilidad aplicable a toda hipótesis de culpa.

Esta regla general encontró su expresión más célebre en el artículo 1382 del Código Civil francés (1804): "Todo hecho cualquiera del hombre que causa daño a otro, obliga a aquel por cuya culpa ocurrió a repararlo". ANDRÉS BELLO siguió esta tradición al redactar el artículo 2314 del Código Civil chileno, que tomó como fuentes las Siete Partidas y, principalmente, la tradición jurídica moderna de inspiración francesa. Así, el Código de 1855 consagra la responsabilidad por culpa como principio general, en un momento histórico en que "nadie discutía ni ponía en duda la necesidad de la culpa o dolo de parte del autor del daño para comprometer su responsabilidad" (ALESSANDRI).

c) Tendencias contemporáneas

Los principios generales de responsabilidad por culpa establecidos a partir del siglo XIX se mantienen hasta nuestros días como criterios básicos para atribuir responsabilidad. Sin embargo, la evolución del sistema en el último siglo ha estado marcada por tendencias que han cruzado transversalmente todos los ordenamientos:

- **Objetivación de la culpa.** El concepto civil de culpa tiene desde el derecho romano una connotación objetiva: supone comparar la conducta efectiva del autor con un estándar general de conducta (el del buen padre de familia o el del profesional razonable). Esta característica ha favorecido la expansión de la responsabilidad, simplificando la prueba y estableciendo estándares generales adaptables.
- **Expansión de las presunciones de responsabilidad.** La creciente desigualdad probatoria entre la víctima y el potencial causante del daño —que frecuentemente controla la información relevante— ha justificado el desarrollo de presunciones de culpa, que invierten la carga de la prueba e impiden que queden impunes accidentes culpables difíciles de demostrar para la víctima.

- **Proliferación de estatutos de responsabilidad objetiva.** Para ciertos ámbitos de riesgo especialmente intenso —actividades industriales peligrosas, daños ambientales, productos defectuosos en el derecho comparado— el estatuto general de culpa ha sido sustituido por regímenes de responsabilidad estricta, establecidos por leyes especiales.
- **Expansión del daño moral.** Uno de los desarrollos más importantes del derecho contemporáneo de la responsabilidad civil es la aceptación de la reparación de los daños no patrimoniales. Bajo la influencia de los derechos de la personalidad y del principio de reparación integral, los tribunales han reconocido progresivamente la resarcibilidad del daño moral, pese a las restricciones que el propio Código Civil establece en algunos preceptos (art. 2331).
- **Interrelación con el seguro obligatorio.** La generalización de los seguros obligatorios para actividades riesgosas ha transformado la posición de la responsabilidad civil en el sistema de atribución de costos por accidentes, convirtiéndola en un estatuto supletorio que opera principalmente para obtener la reparación de los daños no cubiertos por el seguro y, en particular, el daño moral.

PAUSA — COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado la **Sección 2 — Fundamentos, principios y evolución histórica**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

3. DIFERENCIAS Y RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD PENAL

3.1. Independencia de ambas responsabilidades

La responsabilidad civil y la responsabilidad penal son regímenes jurídicos independientes entre sí. Esta autonomía significa que la existencia de una no implica la existencia de la otra: puede haber responsabilidad penal sin que exista responsabilidad civil —cuando el hecho ilícito penal no ocasiona daño a un tercero determinado—, y es usual que haya responsabilidad civil sin responsabilidad penal, como ocurre cuando el hecho que ocasiona el daño no está tipificado como delito o constituye meramente un cuasidelito civil sin relevancia penal.

El propio artículo **2314** del Código Civil reconoce esta independencia al señalar que la obligación de indemnizar perjuicios opera "sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito". Así, frente a un mismo hecho pueden derivarse en paralelo una acción penal —cuya finalidad es la imposición de una pena— y una acción civil de responsabilidad extracontractual —cuyo objeto es la reparación del daño—.

3.2. Principales diferencias entre ambos regímenes

a) Tipicidad del ilícito

La diferencia más profunda entre ambos sistemas de responsabilidad reside en el principio de tipicidad, que rige con plena vigencia en el derecho penal pero carece de aplicación en el derecho civil. En materia penal, el principio de legalidad exige que la conducta sancionada se adecue exactamente a la descripción contenida en la ley con anterioridad a su comisión (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). La conducta penal debe estar previamente tipificada, y el juez no puede crear tipos penales a partir de principios generales.

En materia civil, en cambio, la ilicitud de la conducta consiste en la infracción a un deber general de cuidado que puede haber sido establecido con anterioridad por la ley —hipótesis de culpa infraccional— o que puede ser determinado por el juez con posterioridad al hecho juzgado. Dado que la conducta humana admite una variedad inabordable de formas, el legislador no puede definir exhaustivamente todos los deberes de cuidado exigibles, de modo que la mayoría de ellos quedan entregados a la apreciación prudencial del tribunal. Esta apertura del sistema civil es lo que permite al derecho de la responsabilidad adaptarse a nuevas situaciones de riesgo sin necesidad de modificación legislativa.

b) El daño como requisito esencial

En materia civil, el daño es un requisito *esencial e indispensable* para que nazca la responsabilidad. Sin daño no hay responsabilidad extracontractual. El artículo **2314** del Código Civil exige expresamente que el hecho ilícito haya "inferido daño a otro", y el artículo **2329** reitera que lo que se debe reparar es el "daño" imputable a malicia o negligencia.

En el derecho penal, en cambio, no se requiere la existencia de un daño efectivo para atribuir responsabilidad. La ley penal contempla figuras delictivas de *mero peligro*, que sancionan la puesta en riesgo de bienes jurídicos protegidos con independencia de si el riesgo efectivamente se materializó en un daño. Asimismo, el derecho penal sanciona la *tentativa* y el *delito frustrado*: conductas que el autor comenzó a ejecutar con ánimo de consumar el delito, pero que no produjeron el resultado típico. En el sistema civil, en cambio, una conducta culpable que no produce daño alguno no genera responsabilidad.

Diferencia fundamental: el daño en civil vs. el resultado en penal

En responsabilidad extracontractual, sin daño no hay responsabilidad. En derecho penal, la responsabilidad puede nacer del solo peligro creado o de la mera tentativa, sin que se produzca un resultado lesivo. La Corte de Apelaciones de Iquique (18 de junio de 1953) lo expuso con precisión: "la característica esencial del delito civil consiste en que el hecho ilícito que importa inferir injuria o daño a otra persona, circunstancia ésta que marca su diferenciación con el delito penal".

c) Intensidad de los requisitos subjetivos: capacidad y culpabilidad

Los requisitos de imputabilidad subjetiva son más exigentes en el derecho penal que en el civil. En materia de capacidad, la responsabilidad extracontractual civil

es más amplia que la penal y que la civil contractual: los requisitos de capacidad que el artículo 2319 establece en materia extracontractual son extraordinariamente tenues —incapacidad de los menores de 7 años y de quienes, siendo mayores de 7 y menores de 16, actuaron sin discernimiento—, en tanto que la legislación penal establece una edad mínima de responsabilidad de 14 años (Ley N.º 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente).

En cuanto a la culpabilidad, el juicio penal exige una indagación profunda sobre el estado psíquico del autor —dolo directo, dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente— con un marcado componente subjetivo. El concepto civil de culpa, en cambio, tiene desde el derecho romano una connotación esencialmente *objetiva*: el juicio no recae en la reprochabilidad moral del autor, sino en la comparación entre su conducta efectiva y el estándar de conducta que el ordenamiento le exige. Esta objetivación de la culpa civil explica que la responsabilidad civil pueda recaer sobre personas cuya culpabilidad personal sería muy discutible desde una perspectiva moral o penal.

d) Finalidades distintas

Las finalidades de ambos sistemas son esencialmente distintas. La responsabilidad penal persigue sancionar conductas socialmente intolerables mediante la imposición de penas que el Estado aplica en ejercicio del ius puniendi. La responsabilidad civil extracontractual, en cambio, persigue la reparación del daño particular sufrido por la víctima: es una relación bilateral entre el causante del daño y quien lo padece, no entre el Estado y el infractor. De ahí que la indemnización civil se mida por el daño efectivamente sufrido —principio de reparación integral— y no por la gravedad de la conducta ilícita.

3.3. Influencia de la sentencia penal en sede civil

Aunque ambas responsabilidades son independientes, la sentencia penal puede producir efectos sobre la acción civil de responsabilidad. El Código de Procedimiento Civil regula esta interferencia en los artículos 178 y 179.

La **sentencia condenatoria penal** produce cosa juzgada en el proceso civil en lo relativo a la existencia del hecho punible y a la participación del condenado (art. 178 CPC): "En los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al reo." Esto implica que si el autor del hecho ilícito fue condenado penalmente, la víctima puede invocar esa sentencia en el juicio civil sin necesidad de volver a probar la existencia del hecho y la participación del condenado.

La **sentencia absolutoria penal**, en cambio, por regla general no produce cosa juzgada en materia civil. De la circunstancia de que no exista responsabilidad penal no se sigue necesariamente que tampoco exista responsabilidad civil. Así lo establece el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil: las sentencias que absuelvan de la acusación o que ordenen el sobreseimiento definitivo solo producen cosa juzgada en materia civil cuando se fundan en alguna de las causales taxativamente señaladas por esa disposición —como haberse establecido la inexistencia del hecho o la participación del imputado—. En los demás casos, el juicio civil puede proseguir con independencia del resultado del proceso penal.

Dato de grado — Efectos de la sentencia penal en sede civil

- **Sentencia condenatoria penal** → produce cosa juzgada en civil respecto del hecho y la participación (art. 178 CPC).
- **Sentencia absolutoria penal** → por regla general NO produce cosa juzgada en civil (art. 179 CPC); excepcionalmente sí lo produce cuando la absolución se funda en la inexistencia del hecho o la no participación del imputado (causales del art. 179).
- Razón: los requisitos de la responsabilidad penal son más exigentes que los de la civil; la absolución penal puede deberse a causas que no excluyen la responsabilidad civil (e.g., falta de dolo penal no excluye culpa civil).

PAUSA — COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado la **Sección 3 — Diferencias y relación con la responsabilidad penal**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

4. DIFERENCIAS Y RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

4.1. El debate sobre la dualidad o unidad del sistema

El ordenamiento civil chileno reconoce dos grandes estatutos de responsabilidad civil: el contractual y el extracontractual. Esta dualidad es característica de los sistemas de tradición romano-germánica, y ha generado un importante debate doctrinario: ¿son estos dos regímenes esencialmente distintos, o deberían ser unificados bajo un estatuto general?

Parte de la doctrina comparada —especialmente en el área francófona— ha propugnado la unificación de ambos regímenes bajo un estatuto único, atendiendo a que comparten el mismo objetivo: la reparación pecuniaria del daño sufrido por el hecho de un tercero. YZQUIERDO TOLSADA y otros autores han sostenido que las diferencias entre ambos estatutos son de carácter técnico, no de naturaleza, y que un tratamiento unitario permitiría alcanzar mayor coherencia sistémica.

La posición dominante, sin embargo, mantiene la distinción entre ambos regímenes, argumentando que las diferencias no son meramente técnicas sino que responden a diversidades estructurales relevantes. En el derecho chileno, esta distinción se mantiene plenamente, aunque la jurisprudencia ha tendido en algunos casos a aproximar los estándares de ambos regímenes —especialmente en materia de daño moral y de extensión de la reparación—.

4.2. Diferencias principales entre responsabilidad contractual y extracontractual

a) Origen de la obligación: vínculo previo y carácter de la responsabilidad

La diferencia estructural más fundamental entre ambos estatutos reside en la relación preexistente entre el causante del daño y la víctima. La responsabilidad contractual presupone la existencia de un vínculo obligatorio anterior —un contrato— entre deudor y acreedor: la obligación de indemnizar es consecuencia del incumplimiento de esa obligación preexistente, y por ello tiene un carácter *secundario* o de segundo grado. La responsabilidad extracontractual, en cambio, no supone vínculo obligatorio previo alguno; la obligación de indemnizar nace directamente del hecho ilícito, y por ello tiene carácter *originario* o de primer grado. El vínculo obligatorio entre el causante del daño y la víctima surge precisamente de ese hecho.

b) Prueba de la culpa

En materia contractual, la culpa del deudor se *presume*: el acreedor solo debe probar la existencia de la obligación y el incumplimiento, y corresponde al deudor acreditar que empleó el cuidado debido o que el incumplimiento se debió a caso fortuito (art. 1547). En materia extracontractual, la regla general es la inversa: la víctima debe probar la culpa del autor del daño, según los principios generales sobre carga de la prueba. Esta diferencia se atenúa por la existencia de presunciones de culpa en el propio estatuto extracontractual (arts. 2320, 2322 y 2329), que invierten la carga de la prueba en hipótesis específicas; pero la regla de base —carga sobre la víctima— se mantiene.

c) Prescripción

Los plazos de prescripción son distintos en ambos estatutos. La acción de responsabilidad contractual prescribe en el plazo general de **5 años**, contado desde que la obligación se hizo exigible (art. 2515). La acción de responsabilidad extracontractual prescribe en el plazo especial de **4 años**, contado desde la perpetración del acto ilícito (art. **2332**).

La jurisprudencia ha debatido en torno al punto de inicio de este plazo de cuatro años: si se cuenta desde que el hecho ilícito se cometió o desde que la víctima tuvo o debió haber tenido conocimiento del daño. La posición dominante sostiene que el dies a quo es la comisión del hecho ilícito, con prescindencia del conocimiento de la víctima, aunque en la práctica los tribunales han morigerado esta regla en casos en que el daño se manifestó con posterioridad al hecho que lo causó.

d) Solidaridad entre los responsables

En materia extracontractual, el artículo **2317** establece que "si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito". La solidaridad opera de pleno derecho, sin necesidad de estipulación ni de disposición legal especial. En materia contractual, en cambio, la solidaridad no se presume y solo existe cuando ha sido expresamente convenida o establecida por la ley (art. 1511).

e) Graduación de la culpa

El Código Civil establece en materia contractual una graduación tripartita de la culpa —grave, leve y levísima— con efectos en la determinación de la responsabilidad según el tipo de contrato (art. 44 CC). En materia extracontractual, en cambio, esta graduación carece de relevancia: el sistema solo atiende a si la conducta infracciona o no el deber de cuidado exigible según el estándar del hombre prudente o del profesional razonable. La gravedad de la culpa no incide en la extensión de la indemnización, que siempre se mide por el daño efectivo y no por la intensidad del ilícito.

f) El daño moral

La resarcibilidad del daño moral ha sido históricamente pacífica en materia extracontractual: el artículo 2329 impone la reparación de "todo daño" imputable a culpa o dolo, y la jurisprudencia reconoce sistemáticamente la indemnización del daño moral en este ámbito. En materia contractual, en cambio, la procedencia del daño moral fue objeto de un largo debate, pues el artículo 1556 del Código Civil limita la indemnización a los perjuicios consistentes en el "daño emergente" o el "lucro cesante", sin mención del daño moral. La tendencia jurisprudencial mayoritaria actual admite el daño moral en sede contractual, pero el debate no está completamente cerrado, lo que constituye una diferencia práctica relevante entre ambos estatutos.

g) Capacidad

Las reglas de capacidad difieren en ambos regímenes. En materia contractual, la capacidad para contratar sigue las reglas generales del artículo 1446 y siguientes: los relativamente incapaces pueden actuar con la intervención de sus representantes legales. En materia extracontractual, el artículo 2319 establece reglas propias: son incapaces de delito o cuasidelito los menores de 7 años (infantes) y los mayores de 7 y menores de 16 años que actuaron sin discernimiento, según calificación judicial. Los mayores de 16 años son plenamente capaces en materia extracontractual. La responsabilidad civil extracontractual es, en este sentido, *más amplia* que la contractual y que la penal en cuanto al ámbito de personas que pueden incurrir en ella.

h) La mora

En materia contractual, la mora del deudor es un requisito para que nazca la obligación de indemnizar los perjuicios, salvo en los casos de mora automática establecidos por la ley o cuando la obligación es de no hacer (art. 1551). En materia extracontractual, en cambio, la obligación de indemnizar nace directamente del hecho ilícito, sin necesidad de interpelación del deudor: el causante del daño queda obligado desde el momento en que lo causó, y los intereses sobre la indemnización corren desde esa fecha.

Dato de grado — Cuadro comparativo: responsabilidad contractual vs. extracontractual

Aspecto	Responsabilidad contractual	Responsabilidad extracontractual
Origen de la obligación	Incumplimiento de obligación preexistente (2.º grado)	Hecho ilícito sin vínculo previo (1.º grado / originaria)
Prueba de la culpa	Se presume (art. 1547); deudor debe probar diligencia	La víctima debe probarla (regla general)
Prescripción	5 años (art. 2515)	4 años desde el hecho (art. 2332)
Solidaridad	No se presume; solo por convención o ley (art. 1511)	Opera de pleno derecho (art. 2317)
Graduación de culpa	Grave, leve, levísima (art. 44)	Solo culpa leve como referencia
Daño moral	Debatido; mayoría lo admite actualmente	Plenamente reconocido (art. 2329)
Capacidad	Reglas generales (art. 1446 y ss.)	Reglas propias: incapaces < 7 años; 7-16 según discernimiento (art. 2319)
Mora	Requiere interpelación (art. 1551)	No se requiere; la obligación nace con el hecho

4.3. La regla general o derecho común de responsabilidad civil

El legislador chileno no estableció expresamente cuál es el régimen común de responsabilidad civil aplicable a las situaciones no reguladas específicamente. Esta omisión ha dado lugar a un debate doctrinario relevante: ¿es el estatuto contractual o el extracontractual el que ocupa la posición de derecho común?

Una corriente encabezada por ALESSANDRI sostuvo que el régimen común es el contractual, por encontrarse regulado genéricamente en el Título XII del Libro IV del Código Civil, "Del efecto de las obligaciones", y porque en ese estatuto se encuentran las graduaciones de culpa que también aparecen en normas sobre obligaciones legales y cuasicontractuales. A este argumento se añade que las obligaciones extracontractuales son, para este autor, de carácter excepcional.

La posición contraria, que BARROS considera más correcta, afirma que el régimen común es el extracontractual, porque se refiere precisamente a las relaciones no regidas por un vínculo obligatorio preexistente, que son la regla en el tráfico espontáneo entre personas que no tienen un contrato previo. El contrato supone necesariamente un acuerdo anticipado, que no existe en la gran mayoría de los encuentros entre personas en la vida social. Por ello, en la práctica, el estatuto que opera como régimen residual es el extracontractual.

La cuestión se torna especialmente debatida en los casos en que existe una obligación preexistente de fuente legal —no contractual—, como la obligación de dar alimentos o la responsabilidad de los directores de sociedades anónimas respecto de los accionistas. En estos supuestos, parte de la doctrina propugna la aplicación

analógica del estatuto contractual, por tratarse del incumplimiento de una obligación personal; otro sector aplica el estatuto extracontractual.

4.4. El problema del cúmulo o concurrencia de responsabilidades

En determinadas situaciones, un mismo hecho puede generar simultáneamente responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. Esta superposición se produce cuando entre el causante del daño y la víctima existe un contrato, y el daño que sufre la víctima podría ser calificado tanto como incumplimiento contractual como hecho ilícito extracontractual. El problema clásico es si, en tal caso, la víctima puede elegir libremente entre ejercer la acción contractual o la extracontractual, o si está obligada a fundar su acción en el contrato.

Este problema —conocido como "cúmulo" o "concurso" de responsabilidades— se analiza en detalle en la Sección 8 del presente manual. Baste señalar aquí que la solución depende de la interpretación que se dé al artículo 1437 y al alcance del efecto relativo de los contratos. La posición dominante en Chile inclina por el sistema de "no acumulación" u "opción": la víctima debe, en principio, ejercer la acción correspondiente al estatuto contractual cuando el daño se produjo en el marco de una relación contractual, sin poder "optar" por el estatuto extracontractual para aprovechar sus disposiciones más favorables.

Atención — Concurrencia de responsabilidades: anticipación

El problema del cúmulo o concurrencia de responsabilidades se trata en extenso en la Sección 8. En el examen de grado suele preguntarse específicamente: (1) cuándo se produce la concurrencia; (2) si la víctima puede optar entre el estatuto contractual y el extracontractual; y (3) cuáles son las consecuencias de una u otra opción dado que los regímenes difieren en prescripción, prueba de la culpa y extensión del daño moral. Tener claro el cuadro comparativo de la sección anterior es esencial para responder estas preguntas.

PAUSA — COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado la **Sección 4 — Diferencias y relación con la responsabilidad contractual**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

5. REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

El sistema general de responsabilidad extracontractual por culpa exige la concurrencia de cuatro elementos: (i) un hecho voluntario —acción u omisión—; (ii) la culpa o el dolo del autor; (iii) el daño; y (iv) la relación de causalidad entre la conducta culpable y el daño producido. A estos cuatro requisitos, parte de la doctrina

añade como presupuesto autónomo la capacidad delictual del autor, que en este manual se trata dentro del hecho voluntario, en la subsección 5.1.4.

Todos estos elementos deben concurrir copulativamente para que nazca la obligación de indemnizar. La ausencia de cualquiera de ellos impide que se configure la responsabilidad, con independencia de que los restantes se encuentren plenamente acreditados. El análisis que sigue va elemento por elemento, comenzando por el hecho voluntario.

Dato de grado — Elementos del régimen general

La enumeración clásica de ALESSANDRI comprende: capacidad delictual, culpa o dolo, daño y relación de causalidad. La doctrina moderna —seguida por BARROS— prescinde de la capacidad como elemento autónomo y la integra en el hecho voluntario, resultando: (i) hecho voluntario; (ii) culpa o dolo; (iii) daño; (iv) causalidad. CORRAL agrega la antijuridicidad como elemento separado. El examen exige conocer ambas enumeraciones y explicar sus diferencias.

5.1. El hecho voluntario: acción u omisión

5.1.1. El hecho voluntario como presupuesto de la responsabilidad

La responsabilidad extracontractual tiene por antecedente el *hecho voluntario*. No existe propiamente responsabilidad si no hay un daño reconducible a la conducta libre de un sujeto. Esta exigencia, que parece elemental, es el fundamento de la distinción entre el sujeto responsable y la víctima de un accidente fortuito: solo el primero ha actuado, y solo la conducta humana libre puede ser calificada de lícita o ilícita y originar, en consecuencia, el deber de indemnizar.

El principio se encuentra consagrado expresamente en varias disposiciones del Código Civil. El artículo **1437** señala como fuente de obligaciones "el hecho voluntario de una de las partes", mencionando a continuación los delitos y cuasidelitos. El artículo **2284** precisa que el delito es el "hecho ilícito cometido con intención de dañar" y el cuasidelito el "hecho culpable cometido sin intención de dañar". Por su parte, el artículo **2314** exige que el causante "haya cometido" un delito o cuasidelito, lo que supone un obrar humano atribuible a su agente. Finalmente, el artículo **2329** impone la reparación de "todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona", haciendo de la imputación el eje del sistema.

El hecho voluntario admite una doble dimensión analítica: una *dimensión material*, referida a la conducta objetivamente considerada —acción u omisión—; y una *dimensión subjetiva*, que alude a la voluntariedad o libertad del acto, esto es, a la existencia de un mínimo de control del agente sobre su propia conducta.

5.1.2. La dimensión material: acción y omisión

En su dimensión material, el hecho voluntario se manifiesta como un comportamiento positivo (la *acción*) o negativo (la *omisión*). La regla general es que los daños jurídicamente relevantes son los producidos a consecuencia de una *acción*: quien golpea a otro, quien conduce un vehículo de modo imprudente, quien fabrica un producto defectuoso, actúa positivamente y con ello interfiere en la esfera

jurídica protegida de la víctima. La acción es, en este sentido, el supuesto típico del hecho ilícito.

La *omisión*, en cambio, plantea requisitos más exigentes. No toda inacción ante el daño ajeno genera responsabilidad: el mero espectador que presencia un accidente sin intervenir no incurre, por ese solo hecho, en responsabilidad. La omisión da lugar a responsabilidad solo cuando el deber general de cuidado prescribía al agente asumir una determinada conducta activa y este no la ejecutó. En otros términos, la omisión solo es relevante cuando existe un *deber especial de actuar*: una obligación jurídica —legal, convencional o derivada de la posición de garante del agente— que le imponía intervenir para evitar el daño.

Acción vs. omisión: diferencia fundamental

La acción genera responsabilidad cuando infringe un deber general de no dañar (*alterum non laedere*). La omisión, en cambio, solo la genera cuando existe un deber especial de actuar. La pregunta relevante en la omisión no es "¿debí no dañar?" sino "¿tenía la obligación jurídica de actuar para evitar este daño?". Ese deber puede surgir de la ley (el médico de guardia, el conductor que atropella), del contrato (el salvavidas), de la conducta anterior del propio agente (quien crea un riesgo tiene deber de neutralizarlo) o de la posición de garante del demandado respecto de la víctima.

La doctrina distingue entre la *culpa de comisión* —se ejecuta una acción que no debió realizarse— y la *culpa de omisión* —se omite una conducta que debió ejecutarse—. El juicio de culpabilidad en la omisión plantea cuestiones específicas, porque supone determinar no solo cuál era el estándar de conducta exigible, sino previamente si existía el deber de actuar que da relevancia jurídica a la inacción. Por eso, BARROS advierte que "el comportamiento negativo, la pura omisión, está sujeto a requisitos particularmente exigentes para dar lugar a responsabilidad".

Ejemplos de omisión relevante

Médico de urgencias: El médico de turno que omite atender a un paciente en estado crítico incurre en responsabilidad por omisión, porque su posición de garante le impone el deber de actuar. **Propietario de local:** El dueño de un establecimiento que no repara una escalera en mal estado y un cliente cae responde por omisión, porque la ley le impone el deber de mantener sus instalaciones en condiciones seguras. **Conductor que atropella:** Quien atropella a un peatón y no lo socorre infringe el deber de socorro del artículo 176 de la Ley del Tránsito, configurando una omisión ilícita adicional al hecho positivo del atropello.

5.1.3. La dimensión subjetiva: la voluntariedad del acto

La dimensión subjetiva del hecho voluntario exige que la conducta —acción u omisión— sea atribuible a su autor como acto libre. La responsabilidad civil ha reducido al mínimo las exigencias de subjetividad: basta que el agente haya tenido control sobre su conducta para que esta pueda serle imputada. No se requiere, como en el derecho penal, un juicio profundo de reproche personal; no es necesario siquiera que el sujeto conozca los efectos de su conducta. Basta que la controle.

Este rasgo mínimo de la voluntariedad se agota, según BARROS, en el "*simple control sobre la propia conducta*". Establecida esa voluntariedad elemental, resultan irrelevantes para fundar la responsabilidad las debilidades personales, la torpeza, la inexperiencia o la ignorancia del autor. Estos factores no excusan, porque sus efectos deben ser soportados por el propio agente y no cargados a la víctima. Aquí radica una diferencia esencial con el derecho penal, donde la culpabilidad exige un juicio subjetivo más profundo que incluye el conocimiento de la ilicitud y la exigibilidad de una conducta alternativa conforme a derecho.

5.1.4. La capacidad delictual

La voluntariedad de la acción presupone que su autor tenga la aptitud mínima de deliberación necesaria para discernir lo que es correcto: esa aptitud es la **capacidad delictual** o de imputabilidad. Por eso se la estudia aquí, como condición del hecho voluntario —en rigor, anterior a todos los demás requisitos—: solo de quien es capaz puede predicarse una conducta libre que le sea atribuible. La capacidad muestra el carácter *retributivo* que conserva la responsabilidad civil, pues exige en el agente un grado mínimo de discernimiento.

La **regla general es la capacidad** (art. 1446), y en materia extracontractual lo es con mayor amplitud aún que en los demás campos del derecho. De ahí que el estudio de la capacidad delictual se resuelva, en la práctica, en el análisis de las **incapacidades**, que el artículo 2319 reduce a dos causas: la *demencia* y la *minoría de edad*.

Dato de grado — La capacidad delictual es la más amplia del ordenamiento

Conviene tener presente el contraste de umbrales, frecuente en el examen:

- **Capacidad extracontractual:** plena a los **16 años** (y entre 7 y 16 según el discernimiento que aprecie el juez). Es la más amplia.
- **Capacidad contractual:** plena a los **18 años** (art. 1447 y 26).
- **Capacidad penal:** plena a los **18 años**; régimen especial de responsabilidad penal adolescente entre los 14 y los 18 (Ley N.º 20.084).

La razón, según ALESSANDRI, es que "el hombre adquiere la noción del bien y del mal mucho antes que la madurez y la experiencia necesarias para actuar en la vida de los negocios".

a) Incapacidad del demente. Demente es, genéricamente, la persona privada de razón por causas patológicas al tiempo de ejecutar el hecho. Su determinación es una cuestión de *hecho* —debe probarse en el juicio—, pero también *normativa*, porque el concepto jurídico de demencia no coincide con el médico, ni es idéntico en sede contractual y extracontractual. Dos consecuencias importantes derivan de ello:

- El **decreto de interdicción** no produce en sede extracontractual los efectos permanentes e irrefutables que tiene en materia contractual (arts. 456 y 465): aquí es solo un *antecedente* que podrá fundar una declaración judicial específica de demencia. Por eso —al menos en teoría— el interdicto por demencia puede ser tenido por *capaz* para efectos de su responsabilidad aquiliana, pues una persona puede ser incapaz de administrar sus bienes y conservar, sin embargo, el discernimiento del límite entre lo correcto y lo incorrecto. Ello es coherente con que los requisitos de capacidad contractual sean más exigentes que los de la extracontractual.
- La doctrina (BOETSCH) exige que la demencia sea **actual** (al momento del hecho), **total** (privación absoluta de la aptitud de darse cuenta del acto) y **no imputable a la voluntad del propio sujeto** —principio que se aprecia en la regla del ebrio—. La prueba de la demencia corresponde a quien la alega como excusa, conforme a la presunción general de capacidad.

El **ebrio** —y, por extensión, quien actúa bajo el efecto de drogas— constituye una aplicación de ese tercer requisito: responde del daño causado (art. 2318) porque su privación de razón le es imputable (*actio libera in causa*). Esta hipótesis se desarrolla en la subsección 5.1.6.

b) Incapacidad del menor. El artículo 2319 distingue dos situaciones:

- **Infantes** —menores de **siete años** (art. 26)—: son absolutamente incapaces de delito o cuasidelito.
- **Mayores de siete y menores de dieciséis años:** en principio capaces, pero queda "a la prudencia del juez determinar si el menor de 16 años ha cometido el delito o cuasidelito *sin discernimiento*". La plena capacidad se adquiere, así, a los dieciséis años, pero puede extenderse hacia abajo —hasta los siete— según el juicio de discernimiento.

El **discernimiento** exige que el menor haya podido comprender la incorrección de su acto y apreciar mínimamente su riesgo. Se juzga *en concreto*, atendiendo a las circunstancias del niño y del peligro: puede presumirse respecto de conductas cuya incorrección es intuitivamente conocida por niños de su edad, y negarse cuando se trata de riesgos que el menor no estaba en condiciones de valorar. Se trata de una facultad prudencial del juez, expresiva de la *liberalidad* del derecho civil en materia de capacidad: en la duda, el menor se tiene por responsable, salvo que se acredite su falta de discernimiento.

Ejemplo — El juicio de discernimiento

Se ha tenido por responsable al menor de doce años que, manejando un arma de fuego, no evitó dirigirla cargada hacia quien pasaba frente a él, causándole la muerte: la peligrosidad de un arma es intuitivamente comprensible a esa edad. En cambio, no habría discernimiento —enseña BARROS— si un niño de ocho años, sin experiencia tecnológica previa, presiona por curiosidad una tecla de un computador a su alcance y borra información valiosa: el riesgo de esa acción escapa a su capacidad de valoración.

c) Responsabilidad del guardián del incapaz. Como la falta de capacidad excluye la responsabilidad, frente al hecho de un incapaz la víctima quedaría, en principio, privada de reparación. El propio artículo 2319 corrige este resultado: serán responsables de los daños causados por los incapaces "las personas a cuyo cargo

estén, si pudiere imputárseles negligencia". El guardián responde entonces por su *propio* descuido en la vigilancia, no por el hecho del incapaz.

No confundir: art. 2319 (guardián del incapaz) y art. 2320 (responsabilidad por el hecho ajeno)

- **Art. 2319 — guardián del incapaz.** No hay hecho ilícito del incapaz (le falta la capacidad); solo hay responsabilidad *personal y directa* del guardián por su propia negligencia. La víctima **debe probar** esa negligencia. El guardián **no puede repetir** contra el incapaz (a contrario sensu del art. 2325), pues responde de culpa propia.
- **Art. 2320 — hecho ajeno.** Hay *dos* sujetos capaces y dos responsabilidades: la del autor capaz (que debe probarse) y la del tercero que lo tiene bajo su dependencia o cuidado, cuya culpa se **presume**. El tercero que paga **sí puede repetir** contra el autor capaz (art. 2325).

La distinción —además de elegante para el examen— es de pura lógica: solo cabe hablar de responsabilidad por el hecho "ajeno" cuando existe un hecho ilícito ajeno, lo que supone un autor capaz.

Finalmente, las **personas jurídicas** también son capaces de responsabilidad extracontractual —tanto por el hecho propio de sus órganos como por el hecho ajeno de sus dependientes—, materia que por su relación con la voluntariedad del acto se trata en la subsección 5.1.8.

5.1.5. Actos que excluyen la voluntariedad

Son inimputables los actos que no están bajo el control de la voluntad del agente. Esta exclusión opera en las siguientes situaciones:

a) Actos reflejos. Los movimientos que son resultado de reflejos fisiológicos —espasmos, convulsiones involuntarias, reacciones automáticas del sistema nervioso— no constituyen actos de voluntad en ningún sentido jurídico relevante. Quien, a consecuencia de un estornudo involuntario, pierde el control de su mano y daña un objeto ajeno, no actúa voluntariamente y, por ende, no incurre en responsabilidad.

b) Estados de pérdida transitoria del uso de razón. La doctrina distingue entre la demencia —que es una causal de *incapacidad* permanente, tratada en la subsección 5.1.4— y los estados transitorios de pérdida del uso de razón, como el sonambulismo o la hipnosis. En estos casos, siguiendo a CORRAL, no se trata propiamente de incapacidad —pues esta califica a la persona de modo permanente— sino de una causal de exoneración por falta de voluntariedad de la acción en ese momento específico. La ausencia de control sobre la conducta durante el episodio transitorio hace que el daño causado no sea imputable al agente.

c) Fuerza física irresistible. Si el daño es resultado de la actuación del agente bajo la sujeción de una fuerza física externa que le priva absolutamente de la posibilidad de decidir, la conducta no le es imputable. El artículo **1456** del Código Civil puede servir de pauta en esta materia, pues la fuerza que vicia el consentimiento es aquella que priva de la libre determinación de la voluntad. ALESSANDRI señala que en tal caso "las circunstancias contempladas privan de voluntad y sin ésta no hay responsabilidad".

d) Ataques de enfermedades. Los actos cometidos durante un ataque epiléptico u otras crisis de enfermedades que privan de control sobre el propio cuerpo no son imputables al agente. La jurisprudencia ha establecido este principio en sede penal, y la doctrina civil lo extiende por analogía a la responsabilidad extracontractual.

Atención — Estado de necesidad no excluye la voluntariedad

El estado de necesidad —actuar para evitar un mal mayor— no excluye la voluntariedad del acto, sino su ilicitud. Quien actúa en estado de necesidad decide libremente; simplemente lo hace ante una situación de apremio que el ordenamiento considera justificante. Por ello, el estado de necesidad opera como causal de justificación que excluye la antijuridicidad, no como ausencia de voluntad. Esta distinción es importante en el examen: el estado de necesidad se analiza en la sección 5.3 (factores de atribución — causales de justificación).

5.1.6. La situación especial del ebrio y del drogado

El artículo **2318** del Código Civil establece que "el ebrio es responsable del daño causado por su delito o cuasidelito". Esta norma consagra el principio de la *actio libera in causa*: el agente responde por el daño causado durante el estado de privación de razón que él mismo produjo voluntariamente, porque la causa de su estado es un acto libre anterior.

La responsabilidad del ebrio se funda en que su estado de privación de razón le es imputable, pues proviene de un acto voluntario. De ahí que, si se demostrare que la ebriedad no fue voluntaria —porque el agente fue intoxicado por un tercero contra su voluntad mediante fuerza o engaño— puede alegar como excepción la inimputabilidad, y la responsabilidad recaería íntegramente en quien provocó el estado de intoxicación.

ALESSANDRI interpreta el artículo 2318 en términos amplios: el ebrio respondería de los daños que cause durante su estado, sea la ebriedad voluntaria o involuntaria, salvo el caso en que haya sido intoxicado contra su voluntad por un tercero. BARROS, en cambio, funda la responsabilidad específicamente en el carácter voluntario de la conducta que originó el estado, limitando la excepción precisamente a los casos en que la ebriedad no es imputable al agente. La misma regla se extiende a la intoxicación por drogas u otras sustancias que priven de razón.

JURISPRUDENCIA — EBRIEDAD INVOLUNTARIA

Corte Suprema, 10 de octubre de 1985. Se resolvió que quien participó en un hecho delictuoso bajo el efecto del alcohol mezclado subrepticamente por un co-reo con alcaloides y anfetaminas debe considerarse que "participó en el robo privado parcialmente de razón por causas independientes de su voluntad". Si la pérdida de discernimiento no fue voluntaria, el agente puede alegar la inimputabilidad; la responsabilidad recae entonces sobre quien lo colocó en ese estado.

5.1.7. El caso fortuito o fuerza mayor

Una importante causal de supresión de la voluntariedad del hecho —y, por consiguiente, de exoneración de responsabilidad— es el caso fortuito o la fuerza mayor. El artículo 45 del Código Civil lo define como "el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, un apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc."

La doctrina discute cuál es el elemento de la responsabilidad sobre el que actúa el caso fortuito: algunos lo ubican como causal de exclusión de la culpa, otros de la causalidad. Siguiendo a CORRAL —y en esto concuerda BOETSCH— lo más apropiado es ubicarlo como causal de supresión de la voluntariedad del hecho: cuando un daño se produce por caso fortuito, en rigor no puede ser vinculado a una voluntad humana, pues es el evento externo e irresistible el que determina el resultado dañoso, no la conducta del agente.

Elementos del caso fortuito

La doctrina identifica tres requisitos copulativos que debe reunir un hecho para calificar como caso fortuito o fuerza mayor:

a) Irresistibilidad. El evento debe ser insuperable: no es posible evitar sus consecuencias. Este carácter se mide en relación con el deber de diligencia del agente —en forma análoga a la obligación contractual de medios— de modo que la irresistibilidad es relativa al nivel de cuidado exigible. No es irresistible lo que un agente diligente habría podido controlar; sí lo es lo que razonablemente escapa al control de quien actúa con la debida diligencia. La irresistibilidad es el elemento que da nombre a la "fuerza mayor".

b) Imprevisibilidad. El hecho debe ser imprevisible para el agente, atendido el nivel de diligencia que le era exigible. Este es un concepto normativo —no psicológico—: no se trata de lo que el autor en concreto previó, sino de lo que no estaba obligado a prever dadas las circunstancias. El caso fortuito comienza donde cesa el deber de previsión. Por eso, un temblor de grado cinco o seis en la zona central de Chile no es imprevisible para un constructor en esa zona, mientras que el reventón del neumático de un automóvil nuevo sí puede serlo. La imprevisibilidad conecta con la culpa: si el hecho era previsible y evitable para el agente diligente, su ocurrencia revela culpa, no caso fortuito.

c) Exterioridad. El hecho debe ser externo a la esfera de acción y de control del agente. Este requisito es el más propio del caso fortuito desde el punto de vista causal: lo decisivo es que el evento sea ajeno al ámbito de cuidado del demandado. Es indiferente que provenga de la naturaleza o del hecho culpable o no de un tercero, siempre que sea exterior al ámbito de riesgo de quien invoca la exoneración.

Caso fortuito y responsabilidad objetiva

En los regímenes de responsabilidad estricta, la previsibilidad e irresistibilidad pueden no ser excusa suficiente: si el daño fue causado por el riesgo específico que el régimen de responsabilidad objetiva pretende cubrir, no habrá caso fortuito que exonere. En cambio, sí operará como exoneración si el daño se debió a un hecho externo al ámbito de riesgo cubierto por la regla de responsabilidad estricta. Así, el propietario de un vehículo motorizado no puede invocar el caso fortuito si el accidente se debió a la conducción del vehículo (que es precisamente el riesgo cubierto), pero sí si el vehículo fue robado por un tercero que luego causó el accidente.

Dato de grado — Elementos del caso fortuito (para memorizar)

- **Irresistibilidad:** el evento no puede ser evitado, medido conforme al deber de cuidado del agente.
- **Imprevisibilidad:** concepto normativo; lo que el agente no estaba obligado a prever según la diligencia exigible.
- **Exterioridad:** el hecho es ajeno a la esfera de control del demandado; es el elemento puramente causal de los tres.

Los tres elementos deben concurrir copulativamente. La ausencia de cualquiera de ellos impide calificar el hecho como caso fortuito. La carga de probar el caso fortuito recae sobre quien lo invoca como exoneración.

5.1.8. Responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas

El requisito de la voluntariedad del acto plantea la pregunta de si las personas jurídicas —que carecen de voluntad natural— pueden incurrir en responsabilidad civil extracontractual. La respuesta de la doctrina y la jurisprudencia chilenas es afirmativa.

El artículo 58 inciso 2° del Código Procesal Penal (antes artículo 39 del Código de Procedimiento Penal) establece que "la responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas responden los que hubieren intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que las afectare". Esta norma reconoce expresamente la responsabilidad civil extracontractual de las personas jurídicas, aunque la responsabilidad penal quede reservada a las personas naturales que actuaron.

Doctrinalmente, la persona jurídica responde por hecho propio cuando el ilícito ha sido cometido por uno de sus *órganos* en ejercicio de sus funciones. Se entiende por órganos las personas naturales que, actuando individual o colectivamente, están dotadas por la ley o los estatutos de poder autónomo y permanente de decisión —como la junta de accionistas, el directorio y el gerente en una sociedad anónima—. El acto del órgano se atribuye directamente a la persona jurídica, como si fuera su propio acto.

La noción de órgano ha sido extendida también a quienes tienen facultades permanentes de representación de la persona jurídica. Determinar si alguien actúa como órgano o como mero dependiente es una cuestión de hecho que debe analizarse en concreto. Cuando el ilícito no fue cometido por un órgano sino por un de-

pendiente, la persona jurídica responderá no por hecho propio sino por el hecho ajeno, conforme a las reglas del artículo **2320** del Código Civil.

JURISPRUDENCIA — RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE PERSONAS JURÍDICAS

Corte Suprema (criterio general). La doctrina y jurisprudencia nacionales reconocen sin discusión la responsabilidad civil de la persona jurídica, aun cuando el hecho no constituya un ilícito penal. El argumento central es que el artículo 545 del Código Civil no hace distinciones respecto de la capacidad contractual y extracontractual de las personas jurídicas: si pueden obligarse, lo harán también a consecuencia de un delito o cuasidelito cometido por sus órganos o dependientes (DUCCI, ALESSANDRI).

Responsabilidad penal de personas jurídicas (nota). Excepcionalmente, la Ley N.º 20.393 (2009) estableció responsabilidad penal para las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, cuando estos se cometen a favor de la empresa y esta no adoptó modelos de prevención adecuados. Esta es una excepción al principio general de incapacidad penal de las personas jurídicas, que no afecta las reglas de responsabilidad civil extracontractual.

5.2. El daño

5.2.1. Concepto y función

El daño es el presupuesto central de la responsabilidad civil extracontractual. Sin daño, no hay obligación de indemnizar, aunque concurren todos los demás requisitos. El artículo **1437** menciona el daño como fuente de obligaciones, y el artículo **2314** supedita expresamente la responsabilidad del autor del delito o cuasidelito a que este haya "inferido daño a otro". La expresión más amplia se encuentra en el artículo **2329**, que impone la reparación de "todo daño" que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona.

A diferencia de la responsabilidad penal, que sanciona el disvalor de la conducta con independencia del resultado, la responsabilidad civil extracontractual gira en torno al daño efectivamente causado: el delito o cuasidelito frustrado no genera obligación indemnizatoria. El daño es, en palabras de BOETSCH, "una condición de la pretensión indemnizatoria, de modo que ésta sólo nace una vez que el daño se ha manifestado".

En cuanto al concepto, los términos *daño* y *perjuicio* son sinónimos en nuestro ordenamiento y se usan indistintamente. La jurisprudencia lo ha definido como "todo menoscabo que experimenta un individuo en su persona y bienes, la pérdida de un beneficio de índole material o moral, de orden patrimonial o extrapatrimonial".

Dato de grado — El daño como presupuesto sine qua non

La ausencia de daño impide que nazca la obligación indemnizatoria, aunque se acrediten la culpa o el dolo del demandado y la relación de causalidad. Esto distingue radicalmente la responsabilidad civil de la penal. Excepcionalmente, el artículo 2333 del Código Civil permite anticipar la tutela cuando existe un *daño contingente* que amenaza a personas determinadas: en ese caso, puede demandarse la adopción de medidas preventivas aun antes de que el daño se produzca.

5.2.2. Requisitos de resarcibilidad del daño

No todo menoscabo genera obligación de indemnizar. La doctrina y la jurisprudencia han elaborado las condiciones que debe reunir el daño para ser jurídicamente relevante y fundar la acción indemnizatoria. Se enumeran a continuación los siete requisitos de resarcibilidad que recoge BOETSCH, complementados con el análisis de BARROS.

a) Debe lesionar un derecho o un interés legítimo. En principio, solo es indemnizable el daño que afecta a un derecho subjetivo de la víctima. Sin embargo, la concepción ha sido ampliada: también da lugar a indemnización el daño que lesiona un interés legítimo, esto es, un interés que de algún modo se encuentre tutelado por el derecho. La jurisprudencia lo ilustra con el padre extramatrimonial que, sin ser heredero ni acreedor de alimentos, vivía a expensas del hijo fallecido y obtuvo indemnización por el daño a su interés de facto.

En cualquier caso, no todo interés basta: se requiere que sea *legítimo*, lo que excluye los intereses que el ordenamiento no reconoce ni protege. La legitimidad del interés es un filtro que evita que la responsabilidad civil se transforme en instrumento de protección de situaciones jurídicamente reprochables.

b) Debe ser cierto. El daño ha de ser real y efectivo, no meramente hipotético o eventual. La certidumbre no implica que el daño deba ser actual: es plenamente indemnizable el *daño futuro* siempre que, al momento de dictarse sentencia, haya certeza de que necesariamente sobrevendrá. Lo que se exige es certidumbre actual acerca de la existencia y ocurrencia del perjuicio, aunque este se produzca en el futuro. En cambio, el daño *eventual*—aquel cuya existencia no puede afirmarse con un grado razonable de certeza— no es indemnizable.

Certeza del daño futuro vs. daño eventual

El criterio de la certeza no es cronológico sino epistémico: lo que se exige es que el tribunal pueda afirmar con fundamento suficiente que el daño ocurrirá o ha ocurrido. El daño futuro cierto es indemnizable: si un trabajador pierde la mano dominante, es cierto que dejará de percibir sus remuneraciones futuras, aunque estas todavía no se hayan devengado. El daño eventual, en cambio, no lo es: si un candidato afirma que habría obtenido un empleo de no haber sufrido el accidente, pero esa perspectiva era meramente hipotética, el tribunal no puede darla por establecida. Entre ambos extremos se ubica la *pérdida de chance*, que tiene un tratamiento autónomo.

La pérdida de chance o pérdida de oportunidad. La doctrina y la jurisprudencia chilenas reconocen la resarcibilidad de la *pérdida de una chance*, categoría de daño que se ubica entre el daño cierto y el daño eventual: el demandante no puede probar que habría obtenido la ventaja esperada, pero sí puede acreditar que existía una oportunidad seria y concreta de obtenerla, que el ilícito del demandado destruyó.

Como explica TAPIA, en estos casos "existe para la víctima un bien aleatorio que se encontraba en juego (ganar el proceso, cerrar el negocio, recobrar la salud, evitar la muerte, obtener un premio, acceder a una profesión, etc.) y el agente destruyó ese potencial de oportunidades con su acción u omisión negligente". La nota decisiva es el carácter *aleatorio* del bien en juego: aun sin mediar negligencia alguna, la víctima podría no haber obtenido el beneficio o evitado el perjuicio (la demanda pudo rechazarse por otras causas, el negocio pudo frustrarse, el paciente pudo igualmente perecer). Por ello la certeza —y la relación de causalidad— solo alcanzan a la *pérdida de oportunidades*, y no al resultado final. De ahí que la indemnización no equivalga al valor de la ventaja esperada en su totalidad, sino a una estimación proporcional del valor de la chance desaparecida, expresada usualmente como un porcentaje de oportunidades perdidas aplicado al valor total del bien en juego.

RÍOS y SILVA subrayan un límite: las chances no se indemnizan por sí solas; son resarcibles solo cuando representan para la víctima la posibilidad de estar mejor. "No es la privación de una chance en sí lo que la hace indemnizable, sino la concatenación de ésta a un resultado eventualmente más beneficioso para la víctima." Para ser resarcible, la oportunidad debe además ser **seria y real**, y no una mera expectativa conjetural; en el ámbito profesional, ello obliga a ponderar las probabilidades estadísticas de éxito de la acción o gestión frustrada (por ejemplo, las posibilidades de prosperar de un recurso que el abogado dejó precluir, o de sanar con el tratamiento que el médico omitió).

La jurisprudencia ha formulado tempranamente esta categoría como una *zona intermedia*. La Corte de Apelaciones de Concepción, en sentencia de 12 de enero de 2000, sostuvo que entre el daño cierto y el daño eventual existe "una zona intermedia, gris, que es la probabilidad suficiente, que es más que la posibilidad pero menos que la certeza, situación que se conoce en el derecho como chance", quedando entregada a la prudencia del juez la determinación del monto. El riesgo que TAPIA denuncia es que, al no manejar esta categoría, los tribunales tiendan a forzar estos supuestos dentro del *lucro cesante*, con el doble inconveniente de rechazar la reparación (tratando la chance como mera conjetura) o de concederla "completa" (como si hubiese certeza del resultado final), ambas soluciones injustas.

Grupos de casos. En la experiencia chilena la pérdida de chance se presenta de modo recurrente en cuatro ámbitos: (i) *accidentes laborales*, donde a menudo se indemniza bajo el rótulo de lucro cesante lo que en rigor es la pérdida de oportunidades de ingresos futuros; (ii) *responsabilidad de abogados*, por negligencias que privan al cliente de la oportunidad de ganar el pleito (recurso declarado desierto, abandono del procedimiento); (iii) *pérdida de oportunidades de negocios*, que exige acreditar la existencia y entidad concreta de la chance frustrada; y (iv) *responsabilidad médica*, ámbito que concentra el mayor número de casos, cuando la negligencia destruye la oportunidad de sanar, de sobrevivir o de acceder a un mejor tratamiento.

Confirmando a la Corte de Apelaciones de Valparaíso (11 de diciembre de 2008), la Corte Suprema validó el razonamiento en clave de pérdida de chance. Un error de diagnóstico —una biopsia practicada con impericia— no detectó un melanoma maligno, privando a la paciente, durante más de un año, de acceder a un tratamiento adecuado; falleció al año siguiente. El tribunal estimó que *no* podía atribuirse causalmente la muerte al error médico (la diseminación del tumor era previa y no había tratamiento eficaz), pero sí que la negligencia le privó de la "pérdida de posibilidades de un mejor tratamiento y una mayor sobrevida". Para medir la chance ponderó factores esenciales: el carácter irreversible de la enfermedad, la posibilidad de paliar el dolor y la de prolongar la vida. Es el precedente que asume de modo explícito esta categoría en la responsabilidad médica chilena.

Corte Suprema, 6 de enero de 2025 (Rol N.º 242.342-2023). En este fallo, la Corte conoció de la demanda deducida por Alpes Chemie S.A. en contra de CENABAST, fundada en que el organismo público rebajó arbitraria e ilegalmente el puntaje de la demandante en una licitación pública de Inmunoglobulina G humana, lo que fue declarado ilegal por el Tribunal de Contratación Pública.

La Corte rechazó que la acción fuera de lucro cesante —pues la adjudicación era una facultad discrecional de la Administración y no una consecuencia necesaria de haber obtenido el mayor puntaje— y en su lugar reconoció la procedencia de la pérdida de la chance como daño autónomo e independiente del resultado final: la actora no perdió el contrato, pero sí perdió la oportunidad de posicionarse entre los oferentes con mayor puntaje susceptibles de ser adjudicatarios.

Sobre la cuantificación, la Corte señaló que la indemnización por pérdida de chance "no puede ser equivalente al valor que se espera percibir en caso de efectivamente haber obtenido el beneficio perseguido, sino que su cuantía debe ser evaluada en términos más restringidos". Habiéndose establecido que la utilidad máxima esperada equivalía a \$92.378.922 y que tres eran las oferentes con igual probabilidad de adjudicación, la indemnización se fijó en un tercio de ese monto: **\$30.792.974.**

c) Debe ser directo. La relación entre el daño resarcible y el hecho ilícito ha de ser directa, sin intermediarios. El daño indirecto o mediato —aquel que solo se vincula al ilícito a través de causas interpuestas— no es indemnizable, porque en él falla la relación de causalidad. La doctrina ha sintetizado la exigencia señalando que el daño directo es "el que es una consecuencia cierta y necesaria del hecho ilícito".

Se sigue aquí una lógica análoga a la del artículo **1558** del Código Civil en sede contractual.

d) No debe haber sido ya indemnizado. No puede exigirse la indemnización de un perjuicio ya reparado. Este requisito se vincula al principio de reparación integral: la víctima tiene derecho a ser compensada hasta quedar indemne, pero no puede enriquecerse a expensas del responsable. De ahí que, si la víctima ya percibió el pago de una compañía aseguradora, no pueda exigir adicionalmente al responsable la indemnización de los mismos daños —aunque sí de los no cubiertos por el seguro—. A su vez, el asegurador que paga se subroga en los derechos de la víctima para repetir contra el causante del daño (artículo 553 del Código de Comercio).

e) Debe ser de una magnitud suficiente. El sistema jurídico no puede ocuparse de daños mínimos o de las molestias recíprocas que son consecuencia normal de la vida en común. La noción de daño excluye las incomodidades ordinarias de la convivencia —como el ruido normal de un vecino o las interferencias cotidianas en las relaciones de vecindad—. Este requisito opera como un umbral mínimo de relevancia que evita la sobrecarga del sistema judicial con reclamaciones de entidad insignificante.

f) Debate sobre la previsibilidad. Existe desacuerdo doctrinal sobre si el daño debe ser previsible para ser resarcible. La doctrina tradicional (ALESSANDRI) sostiene que en sede extracontractual se indemnizan todos los daños —previstos e imprevistos— que sean consecuencia directa del ilícito, por cuanto el artículo **2329** ordena la reparación de "todo daño" y el artículo **1558**, que introduce la distinción, es de aplicación exclusivamente contractual. BARROS, en cambio, vincula la previsibilidad a la culpa misma: si solo respecto de los daños previsibles pudo el autor obrar imprudentemente, solo ellos deben ser indemnizados. Esta segunda posición ha ganado terreno en la doctrina moderna, aunque la jurisprudencia no ha adoptado una postura uniforme.

g) Debe haber sido personalmente sufrido por la víctima. La acción corresponde a quien personalmente experimentó el daño. Quedan excluidos los *daños difusos* —aquellos que afectan a personas indeterminadas— que solo pueden ser perseguidos a través de acciones colectivas o populares previstas en leyes especiales. La exigencia de daño personal plantea la cuestión del *daño por repercusión o rebote*: el que sufre una persona cercana a la víctima directa como consecuencia del mismo ilícito.

BARROS señala que quienes se ven privados de los ingresos que les proporcionaba la víctima —incluso sin tener derecho legal a alimentos— sufren un daño patrimonial personal (lucro cesante) y tienen acción directa contra el causante. En materia de daño moral por repercusión, la tendencia jurisprudencial exige que entre la víctima mediata y la persona fallecida exista un vínculo de parentesco que justifique la indemnización —típicamente cónyuge, ascendientes y descendientes—, aunque casos particulares han extendido este criterio.

5.2.3. Clasificación del daño

Los daños indemnizables se clasifican atendiendo a la naturaleza del bien lesionado en dos grandes categorías: *daño patrimonial* (o material) y *daño extrapatrimonial* (o moral). Dentro del primero se distinguen el daño emergente y el lucro cesante. La bipartición no es completamente estanca —un mismo hecho puede originar daños de ambas categorías—, pero es estructuralmente relevante porque las reglas de prueba y de evaluación difieren según la naturaleza del daño.

5.2.4. El daño patrimonial

El daño patrimonial es el que consiste en una pérdida o detrimento económico medible en dinero. Se manifiesta en la diferencia entre el estado económico real de la víctima después del accidente y la situación hipotética en que se encontraría si el hecho no hubiera ocurrido. Aunque el artículo 2314 habla simplemente de "daño" y el artículo 2329 de "todo daño" sin distinguir clases, la doctrina y jurisprudencia son unánimes en que el daño patrimonial abarca tanto el daño emergente como el lucro cesante —en paralelo con lo que expresamente dispone el artículo 1556 para la responsabilidad contractual—.

(i) El daño emergente. Es el empobrecimiento real y efectivo que experimenta el patrimonio de la víctima a consecuencia del hecho ilícito. Su efecto es hacer que el activo del patrimonio pese menos. Comprende:

- La destrucción o deterioro de bienes con valor económico. En caso de destrucción total, la indemnización equivale al valor de reposición según el estado previo al hecho; en caso de deterioro, a la suma necesaria para la reparación completa más el eventual menor valor residual de la cosa reparada.
- Los gastos en que debe incurrir la víctima a causa del accidente: hospitalización, honorarios médicos, medicamentos, arriendo de vehículo de reemplazo y similares.
- Los daños económicos o puramente patrimoniales que, sin recaer sobre cosas determinadas, disminuyen el patrimonio: la clientela perdida por un comerciante víctima de competencia desleal, la reducción del valor de un negocio a causa de publicidad engañosa, etc.

(ii) El lucro cesante. Es la pérdida del incremento neto que habría tenido el patrimonio de la víctima de no mediar el hecho ilícito. Lo constituye lo que el actor deja de percibir como consecuencia del ilícito. Se distingue del daño emergente en que no recae sobre un bien ya existente en el patrimonio, sino sobre la ganancia futura que razonablemente se habría incorporado a él.

La jurisprudencia ha precisado que para avaluar el lucro cesante "deben proporcionarse antecedentes más o menos ciertos que permitan determinar una ganancia probable que dejó de percibirse". La *certidumbre* exigida debe entenderse como una probabilidad razonable de ganancia —no como certeza matemática—, lo que obliga a aplicar un cálculo probabilístico. La determinación del lucro cesante "obedece a una proyección del curso normal de los acontecimientos, atendidas las circunstancias particulares de la víctima" (BOETSCH).

Dato de grado — Daño emergente vs. lucro cesante

- **Daño emergente:** empobrecimiento efectivo ya producido; el activo del patrimonio *disminuye*. Ejemplo: costos de hospitalización, valor del vehículo destruido.
- **Lucro cesante:** privación de una ganancia futura; el patrimonio *no aumenta* como debía. Ejemplo: remuneraciones que el lesionado no percibirá durante su incapacidad.
- **Distinción práctica:** si la víctima arrienda un automóvil de reemplazo mientras el suyo es reparado, ese costo es daño emergente. Si simplemente deja de usar el automóvil, la pérdida de uso es lucro cesante.

5.2.5. El daño moral o extrapatrimonial

Concepto. El daño moral es el menoscabo que no recae sobre el patrimonio de la víctima sino sobre bienes o intereses extrapatrimoniales de su persona. Históricamente se lo identificó con el *pretium doloris*: el dolor, pesar o molestia que sufre la persona en su sensibilidad física, en sus sentimientos o en su calidad de vida. Esta noción clásica es hoy considerada insuficiente, pues no abarca todas las manifestaciones del daño extrapatrimonial.

La doctrina moderna prefiere definir el daño moral en sentido amplio, como toda lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, o, en términos negativos, como todo menoscabo no susceptible de evaluación pecuniaria —sinónimo de daño no patrimonial—. Esta definición amplia permite comprender en la reparación todas las categorías de perjuicio extrapatrimonial, sin reducirlas al dolor psíquico. DOMÍNGUEZ HIDALGO, la principal autoridad nacional en la materia, advierte que la identificación del daño moral con el *pretium doloris* es una concepción restrictiva que deja sin reparación todos los atentados a los atributos de la personalidad en los que no exista un quebranto psíquico actual; el daño moral, sostiene, no es sinónimo de afectación de los sentimientos, sino que designa una *categoría* que abarca todo perjuicio de contenido extrapatrimonial.

DOMÍNGUEZ HIDALGO subraya, además, una **asimetría** difícil de justificar entre el tratamiento del daño material y el del daño moral. Mientras el daño emergente se entiende con amplitud —«toda pérdida efectiva experimentada por la víctima»— y otro tanto ocurre con el lucro cesante —«todo lo que se dejó de percibir»—, el daño moral se construye de modo restrictivo, reducido al *precio del dolor*. A esa disparidad se suma un doble estándar probatorio, pues durante mucho tiempo se exigió acreditar el daño material mientras se afirmaba que el moral no requería prueba (cuestión hoy corregida: véase 5.2.6). Para la autora, semejante contraste resulta incompatible con un derecho civil moderno que proclama a la persona —y no al patrimonio— como su objeto primero, y debe corregirse extendiendo al daño moral la misma amplitud conceptual.

La Corte Suprema ha señalado que el daño moral "es la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra. Daño que sin duda no es de naturaleza propiamente económica y no implica, por lo tanto, un deterioro o menoscabo real en el patrimonio de la misma, susceptible de prueba y determinación directa; sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva."

Origen jurisprudencial. El daño moral ha sido en Chile fruto de la creación jurisprudencial: el Código Civil no contiene referencia alguna a esta clase de perjuicio —la única regla sobre el contenido de la indemnización, el artículo 1556, alude solo al daño emergente y al lucro cesante, ambos de carácter patrimonial—. La primera decisión que ordenó indemnizarlo data de 1907, pero el hito que marcó el cambio definitivo es la **sentencia de la Corte Suprema de 16 de diciembre de 1922**, que por primera vez reconoció formalmente la procedencia del daño moral en sede extracontractual (véase el recuadro). Desde entonces su reparación se construyó sobre una reinterpretación amplia del principio *alterum non laedere* recogido en los artículos 2314 y 2329. Su reconocimiento fue pacífico en sede extracontractual mucho antes que en la contractual, donde solo cabe hablar de plena aceptación a partir de las sentencias de 1994 y 2001.

Los hechos. Un niño de ocho años murió atropellado por un tranvía. Su padre, de apellido Grez, demandó a la empresa de transportes (Chilean Electric Tramway and Light Co.) exigiendo una indemnización de 150.000 pesos por la muerte de su hijo. La defensa de la empresa opuso un argumento marcadamente patrimonialista, propio de la época: un niño de esa edad no generaba ingresos sino solo gastos, de modo que no existiría perjuicio económico —daño emergente o lucro cesante— que reparar.

El giro de la Corte. Rompiendo con la tendencia restrictiva decimonónica, el máximo tribunal resolvió que el dolor espiritual y la aflicción psicológica también debían ser resarcidos. Se apoyó en el artículo 2329, interpretando que la expresión "todo daño" no excluye los sufrimientos inmateriales o extrapatrimoniales, y reconoció así, por primera vez en sede aquiliana, el *pretium doloris* de los padres por la muerte de un hijo. La condena efectiva fue de 10.000 pesos —muy inferior a lo solicitado—, pero el valor del fallo es de precedente: a partir de él la jurisprudencia chilena consolidó la procedencia del daño moral en el ámbito extracontractual, criterio que tardaría aún varias décadas en imponerse con igual fuerza en la responsabilidad contractual.

Resarcibilidad. La procedencia de la indemnización del daño moral es hoy pacífica en la doctrina y jurisprudencia chilenas, aunque fue históricamente resistida. Los fundamentos que la justifican son los siguientes:

- El artículo 2329 ordena la reparación de "todo daño", sin distinción entre patrimonial y extrapatrimonial.
- La legislación posterior al Código es confirmatoria: el artículo 19 N.º 7 letra i) de la Constitución Política, el artículo 69 de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo, el artículo 40 de la Ley 19.733 sobre libertad de opinión e información, y el artículo 3 letra e) de la Ley 19.496 sobre protección de los consumidores, reconocen expresamente el daño moral.
- El artículo 2331 del Código Civil, que la doctrina tradicional interpretaba como una exclusión del daño moral para imputaciones injuriosas, fue declarado inaplicable por inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional en 2008. Adicionalmente, la Corte Suprema modificó su interpretación del precepto en sentencia de 7 de junio de 2021 (Rol N.º 6296-2019), concluyendo que la norma no excluye el daño moral, a la luz del principio de reparación integral y de los derechos constitucionales a la integridad y a la honra.

Categorías de daño moral (siguiendo a CORRAL):

- **Daño emocional** (*pretium doloris*): el sufrimiento psíquico que el hecho ilícito causa a la víctima. Es la categoría original y más reconocida.

- **Lesión de derechos de la personalidad:** con independencia del dolor psíquico, existe daño moral cuando se vulnera ilegítimamente un derecho de la personalidad como la honra, la intimidad, la imagen o el derecho de autor. Esta categoría permite que las personas jurídicas sean titulares de daño moral, si se lesionan sus derechos propios de naturaleza extrapatrimonial (buen nombre, reputación, imagen).
- **Perjuicio de agrado o pérdida del disfrute de la vida** (*préjudice d'agrément*; en el derecho inglés, *loss of amenities of life*): la privación de las satisfacciones y actividades —sociales, recreativas, deportivas— que la víctima desarrollaba. Incluye el daño a la calidad y el goce de la vida.
- **Daño corporal o fisiológico:** el menoscabo a la integridad física y psíquica de la persona. Puede traer consecuencias patrimoniales (gastos médicos, lucro cesante) y extrapatrimoniales. ELORRIAGA ha propiciado su autonomía como categoría independiente del daño moral.
- **Daño estético:** la afectación de la apariencia física de la persona, que genera sufrimiento interno y puede requerir reparación autónoma.

Naturaleza objetiva o subjetiva del daño moral. Un punto debatido es si la reparación del daño moral exige que la víctima tenga conciencia del menoscabo que sufre. La cuestión se plantea de modo agudo respecto de víctimas en estado vegetativo, de recién nacidos o de personas con grave deterioro cognitivo. Se enfrentan tres posiciones: (i) la *concepción subjetiva*, que considera la conciencia del daño una condición indispensable de la reparación; (ii) la *concepción objetiva*, que sostiene que la reparación integral no admite excepción por el hecho de que la víctima no tenga conciencia de la pérdida; y (iii) una *tesis intermedia*, que prescinde de la conciencia tanto para los perjuicios patrimoniales como para el *pretium doloris*, pues incluso la víctima inconsciente puede sufrir corporalmente. DOMÍNGUEZ HIDALGO destaca que la jurisprudencia chilena ha optado por la **concepción objetiva**, que importa una apreciación *in abstracto* del daño moral: la reparación se concede atendiendo a la pérdida que, según la experiencia del hombre común, afecta necesariamente a una persona, con independencia de la edad o conciencia que tenga al tiempo de producirse.

Ejemplo — Apreciación in abstracto

La Corte Suprema concedió indemnización del daño moral a dos recién nacidas por la muerte de su padre, pese a que carecían de toda conciencia de la pérdida experimentada. El tribunal razonó que se trata de un menoscabo que, cualquiera sea la edad o el grado de conciencia de la víctima, afecta necesariamente a una persona de acuerdo con la experiencia común. La reparación se concede, pues, en abstracto y no en función de la vivencia psíquica concreta del afectado.

Daño moral de las personas jurídicas. La jurisprudencia chilena ha oscilado en esta materia. El criterio predominante, afirmado por la Corte Suprema desde 2003, es que las personas jurídicas solo pueden reclamar daño extrapatrimonial cuando el menoscabo —aunque de naturaleza inmaterial— tiene consecuencias en el patrimonio de la entidad, como la reducción de clientela o la pérdida de capacidad crediticia derivadas del desprestigio. No procede, en cambio, la indemnización de un daño moral "puro" —sin repercusión patrimonial— para las personas jurídicas, pues estas no pueden sentir ni sufrir en el sentido propio del término.

Corte Suprema, 9 de diciembre de 2003 (Rol 4677-1999). Descartó de plano que una persona jurídica pudiera sufrir perjuicios exclusivamente extrapatrimoniales; solo son indemnizables los que, aunque derivados de un menoscabo al prestigio o la confianza comercial, tengan consecuencias patrimoniales para la entidad.

Tendencia posterior. Las Cortes de Apelaciones de Santiago y Talca han confirmado este criterio: para las personas jurídicas "cabe descartar el concepto de daño moral puro y centrarnos en el daño moral con consecuencias patrimoniales". El demandante debe probar tanto la lesión a la imagen o reputación como las consecuencias económicas concretas que de ella se derivan.

Crítica doctrinal. DOMÍNGUEZ HIDALGO discrepa de este criterio restrictivo. Si el daño moral no se identifica con la mera afectación de los sentimientos, sino con todo atentado extrapatrimonial, no hay razón para descartar su reparación cuando se lesiona la reputación, el prestigio o la imagen de una persona jurídica: la afectación de la credibilidad comercial es, precisamente, un ejemplo de menoscabo no patrimonial. Agrega que, siendo las personas jurídicas titulares de garantías constitucionales (entre ellas el derecho de asociación del artículo 19 N.º 15), sus atributos extrapatrimoniales merecen la protección que ofrece la indemnización del daño moral cuando concurren sus requisitos. La postura mayoritaria de la jurisprudencia, sin embargo, sigue exigiendo repercusión patrimonial.

Art. 2331 y el giro jurisprudencial de 2021. Mediante sentencia de 7 de junio de 2021 (Rol N.º 6296-2019), la Corte Suprema abandonó la interpretación clásica del artículo 2331 y concluyó que la norma no excluye el daño moral en materia de imputaciones injuriosas. Los fundamentos fueron: (a) el principio de reparación integral del artículo 2329; (b) la norma no excluye expresamente el daño moral, sino que simplemente no lo menciona, lo que es explicable porque al tiempo de dictación del Código Civil esa categoría no estaba reconocida; y (c) la exclusión infringiría el artículo 19 N.º 1 (integridad física y psíquica) y N.º 4 (honra) de la Constitución. En el plano doctrinal, DOMÍNGUEZ HIDALGO había sostenido con anterioridad que el artículo 2331 se encuentra *virtualmente derogado* por la Constitución, en cuanto infringe el mandato de tutela amplia de la persona y el principio de reparación integral que de ella se desprende.

Atención — Postura disidente sobre art. 2331

El giro de 2021 no fue unánime. En sentencia de 10 de agosto de 2021 (Rol N.º 22.901-2019), la propia Corte Suprema mantuvo la interpretación tradicional restrictiva. La jurisprudencia no está consolidada en esta materia y en el examen de grado conviene conocer ambas posiciones: (i) la tradicional, que negaba el daño moral en imputaciones injuriosas sin daño patrimonial; y (ii) la reformista de 2021, que lo admite con fundamento en el principio de reparación integral y en la garantía constitucional de la honra.

5.2.6. Prueba del daño

La carga de la prueba del daño recae sobre la víctima, como titular de la pretensión indemnizatoria. El daño es un requisito cuya acreditación es indispensable para que nazca la obligación de indemnizar.

El *daño patrimonial* puede probarse mediante todos los medios de prueba admisibles en derecho. El daño emergente se acredita típicamente con documentos (facturas, boletas, presupuestos de reparación). El lucro cesante, al ser una proyección hipotética de ingresos futuros, se prueba principalmente mediante presunciones e informes periciales que permitan establecer con un grado razonable de probabilidad la ganancia perdida.

En cuanto al *daño moral*, existe una tendencia jurisprudencial a atenuar las exigencias probatorias: en determinadas circunstancias, la ocurrencia del daño moral se infiere de los hechos probados, sin necesidad de una acreditación formal directa. Así, la muerte de un hijo por hecho ilícito genera presumiblemente un daño moral para los padres, sin que se exija prueba explícita del sufrimiento. Sin embargo, la doctrina mayoritaria sostiene que el daño moral debe probarse, adaptando los medios de prueba a su naturaleza intangible. La prueba por presunciones adquiere especial relevancia, siempre que esté fundada en hechos conocidos y probados en el proceso, y que el juez explicita el razonamiento inferencial.

DOMÍNGUEZ HIDALGO precisa que la exigencia de prueba del daño moral no deriva de la naturaleza del perjuicio, sino de los principios probatorios básicos: el daño moral debe acreditarse, y los tribunales pueden *atenuar* esa carga pero nunca *susprimirla*. Las presunciones de daño moral que la jurisprudencia reconoce a favor de quienes estaban ligados afectivamente a la víctima fallecida o lesionada —que dispensan de probar el vínculo de parentesco o afecto— son legítimas en la medida en que siempre admitan prueba en contrario.

5.2.7. Evaluación del daño moral

La evaluación del daño moral es una de las cuestiones más controvertidas del sistema de responsabilidad. Los tribunales enfrentan la dificultad de traducir un concepto intangible a una cifra monetaria, sin que existan parámetros objetivos precisos.

La Corte Suprema ha establecido que la determinación del *monto* del daño es cuestión de hecho, privativa de los jueces del fondo y no susceptible de control por la vía de la casación. Sí es susceptible de revisión la *calificación* del daño (si es moral, eventual, indirecto, etc.), que es cuestión de derecho.

Los criterios de evaluación que emplean los tribunales incluyen: las consecuencias físicas, psíquicas, sociales o morales del daño; las condiciones personales de la víctima; la cercanía o relación afectiva entre el actor y la víctima directa; la gravedad de la conducta del causante; la situación patrimonial de ofendido y ofensor; la clase de derecho o interés extrapatrimonial agredido; y el grado de culpabilidad de ambas partes.

Crítica — La evaluación del daño moral según DOMÍNGUEZ HIDALGO

DOMÍNGUEZ HIDALGO advierte que la evaluación del daño moral en Chile, entregada a la discrecionalidad de los jueces del fondo, adolece de defectos que reclaman revisión: (i) las **condenas «en globo»**, que fijan una suma única sin precisar qué perjuicios extrapatrimoniales se reparan ni con qué criterios; (ii) la **multiplicidad y opacidad de los criterios** empleados, al punto de que numerosas sentencias ni siquiera mencionan los factores ponderados; y (iii) el **uso encubiertamente punitivo** de la indemnización, que se revela cuando el juez atiende a la gravedad del hecho o a la capacidad económica de las partes —factores que, en un esquema puramente resarcitorio, ninguna función deberían cumplir, pues contradicen la regla de que el único parámetro es la magnitud del daño (véase 5.2.8)—. La autora reclama, en su reemplazo, criterios transparentes y sentencias debidamente fundadas.

Dato de grado — Evaluación del daño moral en casación

La Corte Suprema controla únicamente la *calificación jurídica* del daño (¿es patrimonial o moral? ¿es cierto o eventual? ¿es directo o indirecto?), no el *quantum* indemnizatorio. La fijación del monto de la indemnización por daño moral es atribución privativa de los jueces del fondo y no puede ser revisada en casación —salvo que la sentencia carezca de fundamentos suficientes—. Esta es una distinción importante para el examen de grado.

5.2.8. El principio de reparación integral del daño

Formulación. La reparación del daño se gobierna por el **principio de reparación integral**, que ordena restituir a la víctima —en la medida en que el dinero lo permite— a la situación en que se hallaría de no haber sufrido el perjuicio: ni más ni menos que el daño efectivamente padecido. La doctrina lo resume en la fórmula francesa «todo el daño y nada más que el daño», de la que se sigue que el *único parámetro* de la indemnización es la **magnitud del daño**. DOMÍNGUEZ HIDALGO inscribe este principio en una transformación de fondo del derecho de daños: del axioma «no hay responsabilidad sin culpa» se ha pasado al de «todo daño debe ser reparado», de modo que la autora prefiere hablar de una *teoría general de la reparación del daño*, en que la antigua concepción subjetivista —que veía en la responsabilidad un reproche o castigo del ofensor— cede ante la centralidad de la víctima y del perjuicio.

Origen y consagración. Sus primeros indicios se hallan en el derecho romano, con la *Lex Aquilia*; fue con la codificación que adquirió la universalidad que hoy se le reconoce. En Chile se entiende recogido en la regla general de recepción del *alterum non laedere*: el artículo **2329**, conforme al cual «por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta».

Valor normativo. La jerarquía del principio no es una cuestión ociosa: si tuviera rango constitucional, operaría como un *límite al legislador*; si solo tuviera el valor de una ley común, sería plenamente disponible y aun derogable. DOMÍNGUEZ HIDALGO precisa que, en Chile, ninguna Corte le ha reconocido derechamente **rango constitucional**; pero tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional lo han fundado en los artículos **19** N.º 1 (integridad física y psíquica) y N.º 24 (propiedad)

de la Constitución, y se ve reforzado por el artículo 1, que pone al Estado al servicio de la persona humana. La conclusión de la autora es matizada: el principio *no está incorporado* por la Constitución —no tiene rango constitucional—, pero sí *reforzado* por ella, pues integra el ordenamiento jurídico desde la recepción del *alterum non laedere*. Esta precisión es, además, la base de su tesis de que el artículo 2331 se encuentra «virtualmente derogado» por la Constitución (véase 5.2.5).

Las dos vertientes. Del principio se desprenden dos exigencias complementarias. La primera —«todo el daño»— impone una reparación *completa*, que comprende el daño moral en plenitud y en todos los ámbitos de la responsabilidad, contractual y extracontractual; es aquí donde DOMÍNGUEZ HIDALGO sitúa su tesis más característica: **la acción de responsabilidad civil es la única acción civil que se funda exclusivamente en la condición de persona** del perjudicado y constituye, en el marco de la *constitucionalización del derecho civil*, el instrumento más eficiente de tutela de los derechos de la personalidad (honor, integridad, intimidad, imagen). La segunda —«nada más que el daño»— impone el **abandono de toda finalidad punitiva** de la indemnización: adoptada la magnitud del daño como criterio único, quedan descartados los daños punitivos y todo empleo de la reparación como castigo; la indemnización ha de concentrarse en lo que el perjuicio importó para la víctima, y no en la gravedad de la conducta ni en la fortuna del responsable (véase la crítica de 5.2.7).

Distinto alcance en sede contractual y extracontractual. El reconocimiento del principio no es uniforme. En sede **extracontractual** rige en plenitud y sin excepciones: se reparan los perjuicios previstos e imprevistos. En sede **contractual**, en cambio, su recepción es restringida, pues el artículo 1558 excluye los perjuicios imprevisibles al tiempo del contrato, salvo que haya mediado dolo o culpa grave. De ahí que DOMÍNGUEZ HIDALGO observe que la reparación integral es, en el terreno aquiliano, un ideal siempre alcanzable, mientras que en el contractual solo se logra cuando el incumplimiento es doloso. Esta diferencia de extensión es, justamente, uno de los factores que vuelve sensible la cuestión del cúmulo o concurrencia de responsabilidades (Sección 8).

Modificabilidad, límites y orden público. El principio admite modificaciones, pero acotadas. Por *vía convencional* son válidas las cláusulas que limitan o agravan la responsabilidad, con los límites comunes: no pueden alcanzar al dolo —asimilado a la culpa grave—, ni al daño corporal o a la persona, ni configurar cláusulas abusivas a la luz del derecho del consumo; y en sede extracontractual no se admiten pactos anticipados, sino solo acuerdos posteriores por vía de transacción (la materia se desarrolla en la Sección 7). Por *vía legal* existen derogaciones de orden económico —topes o montos máximos en ciertos regímenes especiales— y tarifas —como la del daño por mora en obligaciones de dinero, reducido al interés legal—. En cuanto a la *moderación judicial* por equidad, atendida la situación patrimonial del responsable, DOMÍNGUEZ HIDALGO destaca que el derecho chileno se la **niega** al juez, a diferencia de otros ordenamientos. Por último, la autora sostiene que la reparación integral es un principio de **orden público**, de donde extrae un argumento de control sobre las cláusulas exoneratorias, que pueden vulnerar una garantía que debe asegurarse para todos; con todo, advierte que el principio no es una licencia para ensanchar sin medida el daño resarcible, y que sus excepciones justificadas son perfectamente compatibles con su reconocimiento.

Dato de grado — El principio de reparación integral

Qué es: «todo el daño y nada más que el daño»; el único parámetro de la indemnización es la magnitud del perjuicio. **Dónde se funda:** recepción del *alterum non laedere* en el artículo 2329; reforzado por la Constitución (arts. 19 N.º 1, N.º 24 y 1) pero *sin* rango constitucional (DOMÍNGUEZ HIDALGO). **Dos vertientes:** reparación completa —incluido el daño moral en toda la responsabilidad— y abandono de la finalidad punitiva. **Diferencia clave:** pleno en sede extracontractual; restringido en la contractual por el artículo 1558 (solo integral si hay dolo o culpa grave). **Límites:** cláusulas modificatorias con tope en el dolo, el daño corporal y lo abusivo; sin moderación judicial por equidad en Chile; principio de orden público frente a las cláusulas exoneratorias.

5.3. Factores de atribución y antijuridicidad

Acreditados el hecho voluntario (5.1) y el daño (5.2), resta el elemento que permite *imputar* ese daño a una persona y poner sobre ella el deber de repararlo: el **factor de atribución**. La pregunta que aquí se responde es *por qué* debe responder el demandado, y no la víctima, del daño producido. El derecho chileno conoce dos grandes factores de atribución:

- **La imputación subjetiva** —la *culpa* o el *dolo*—, que constituye el **régimen común y general** de responsabilidad. Se responde porque el daño proviene de una conducta reprochable del agente.
- **La atribución objetiva o estricta** —el *riesgo*—, que es un régimen **excepcional y de derecho estricto**, operante solo donde la ley expresamente prescinde de la culpa. Se responde por haber creado o controlado una fuente de riesgo, con independencia de toda negligencia.

Junto a estos factores, la doctrina discute si la **antijuridicidad** (la ilicitud objetiva de la conducta) constituye un elemento autónomo de la responsabilidad o se subsume en la culpabilidad y en el daño. La cuestión es relevante porque a la antijuridicidad se vinculan las *causales de justificación*, que excluyen la ilicitud y, con ella, la responsabilidad. Esta sección trata, en orden: el dolo y la culpa (imputación subjetiva); el debate sobre la antijuridicidad; las causales de justificación; y la responsabilidad estricta u objetiva.

5.3.1. El dolo

El artículo 44 del Código Civil define el dolo como "la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro". Conforme a la *teoría unitaria del dolo*, este es uno solo en todo el Código —vicio del consentimiento, agravante de la responsabilidad contractual y elemento del delito civil—: siempre la intención del agente de causar daño a otro.

Se trata de un concepto **extremadamente estricto**, que corresponde únicamente al *dolo directo*: aquel en que el autor no solo ha previsto y aceptado el daño, sino que además ha *querido* que ocurra. La definición legal excluye, en principio, el *dolo eventual* —en que el agente no pretende dañar, aunque se representa el daño como posible consecuencia de su acción—. BARROS observa que, en materia civil, la distinción entre dolo directo y eventual carece de mayor importancia práctica, porque el artículo 44 asimila la **culpa grave al dolo**: el extremo descuido —el

que ni las personas negligentes asumirían para sí— produce los mismos efectos que la intención de dañar.

El dolo se aprecia *in concreto*, atendiendo a la efectiva intención del agente, y **no se presume**: su prueba corresponde siempre al demandante (sin perjuicio de las presunciones legales específicas). En cambio, sus consecuencias prácticas sí difieren de las de la culpa, lo que justifica la distinción entre **delito** civil (daño cometido con dolo) y **cuasidelito** civil (daño cometido con culpa) de los artículos **1437**, **2284** y **2314**. Aunque ambos obligan a reparar el daño en igual medida, BOETSCH destaca tres diferencias de régimen:

- Solo en caso de dolo se autoriza la demanda contra el tercero que, sin ser autor ni cómplice, ha *recibido provecho del dolo ajeno* (arts. **1458** y **2316**).
- Las cláusulas de irresponsabilidad no proceden respecto del acto cometido con dolo (art. **1465**).
- Ciertos ilícitos típicos exigen dolo, descartando la responsabilidad por culpa (v. gr. el consejo malicioso del art. **2119**).

5.3.2. La culpa

Concepto. La culpa es la omisión de la diligencia a que se estaba jurídicamente obligado; o, en la fórmula clásica, la falta de aquel cuidado que los hombres prudentes emplean ordinariamente en sus actos o negocios propios. El Código no define especialmente la culpa para los delitos y cuasidelitos, de modo que rige la definición general del artículo **44**, que sigue la noción romana construida sobre patrones *abstractos* de conducta (el buen padre de familia, el hombre juicioso), y no sobre la idea moral de reproche personal.

Apreciación: en abstracto, pero atendidas las circunstancias. La doctrina distingue la culpa *en abstracto* (que compara la conducta del agente con la de una persona prudente expuesta a la misma situación) y la culpa *en concreto* (que atiende a la situación personal del sujeto). La doctrina nacional sostiene casi unánimemente que el Código adopta el criterio **abstracto**, siendo el modelo de comparación el *buen padre de familia* (*bonus pater familias*) del artículo **44**. Ahora bien, la culpa se determina considerando las *circunstancias* de la acción y el rol o calidad del autor (por ejemplo, la de experto): así, la conducta del médico se compara con la de un médico prudente situado en idénticas circunstancias. Esta consideración de las circunstancias no convierte la culpa en subjetiva, pues el rol social se pondera abstractamente.

Dato de grado — El estándar de cuidado: ¿culpa leve o culpa levísima?

Existe un debate clásico sobre el grado de culpa de que se responde en sede extracontractual. Una posición tradicional sostiene que se responde de *toda culpa, incluso la levísima*, porque la clasificación tripartita del artículo 44 (lata, leve, levísima) sería de aplicación estrictamente contractual. La doctrina mayoritaria moderna (BARROS, BOETSCH) responde que el estándar es la **culpa leve**: (i) las referencias del legislador a la culpa en sede aquiliana son genéricas, y el artículo 44 dispone que "culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve"; y (ii) es contradictorio afirmar que la culpa se aprecia conforme al patrón del *hombre prudente* (buen padre de familia) y exigir, a la vez, la esmerada diligencia propia de la culpa levísima. Llevar la exigencia hasta la culpa levísima aproximaría en los hechos la responsabilidad por culpa a la responsabilidad estricta.

Culpa y previsibilidad. La culpa supone la *previsibilidad* de las consecuencias dañosas: el modelo del hombre prudente remite a quien delibera y actúa razonablemente, y lo imprevisible no puede ser objeto de deliberación. La previsibilidad es, justamente, lo que distingue la culpa del caso fortuito (hecho imprevisto e irresistible). De ello se sigue una consecuencia relevante en materia de extensión del daño: como solo respecto de lo previsible pudo el agente obrar imprudentemente, en rigor solo los daños previsibles deberían integrar la obligación de indemnizar (sobre este punto existe el debate ya tratado en 5.2.2, donde la doctrina tradicional —ALESSANDRI— sostiene que en sede extracontractual se indemnizan también los imprevistos).

Culpa infraccional. Es aquella en que los deberes de cuidado han sido fijados por el legislador o por otra autoridad normativa mediante ley, reglamento u ordenanza (límites de velocidad de la Ley del Tránsito, normas de seguridad industrial, legislación ambiental, etc.). Cuando el daño se produce a consecuencia de la infracción de una de estas reglas, el acto es ilícito *per se*: como señala ALESSANDRI, "hay culpa por el solo hecho de que el agente haya ejecutado el acto prohibido o no haya realizado el ordenado por la ley o el reglamento". Con todo, no basta la infracción: se requiere además **relación de causalidad** directa entre la infracción y el daño.

Culpa por acción y por omisión. La culpa puede consistir en obrar no debiendo hacerlo (culpa *in committendo*, imprudencia) o en dejar de actuar (culpa *in omitendo*, negligencia). Lo habitual es la omisión *dentro* del ejercicio de una actividad (no tomar la precaución debida: virar sin señalizar). Más discutida es la responsabilidad por la *mera abstención* —quien, pudiendo salvar a otro sin riesgo grave para sí, no lo hace—, que una corriente admite cuando existe un deber de actuar.

Dato de grado — Naturaleza del juicio de culpabilidad y casación

Establecer los *hechos* que pueden constituir culpa (si hubo choque, si existía un disco "Pare", la velocidad del conductor) es atribución privativa de los jueces del fondo. Pero *calificar* esos hechos —decidir si constituyen culpa, dolo o caso fortuito— es **cuestión de derecho**, pues se trata de conceptos definidos por la ley (art. 44). Por ello, la doctrina nacional sostiene unánimemente que el juicio de culpabilidad es revisable por la Corte Suprema mediante **casación en el fondo**. Distíngase de la *evaluación* del daño (5.2.7), que es cuestión de hecho no revisable.

Prueba de la culpa. Por regla general, la culpa —como el dolo— debe ser probada por quien la alega (art. 1698): la víctima debe acreditar los elementos de la obligación que invoca, entre ellos la culpa. La prueba no tiene restricciones (no rigen las limitaciones a la prueba testimonial de los arts. 1707 y ss., propias de los actos y contratos) y admite presunciones, testigos, confesión y peritajes. La importante excepción a esta regla —las *presunciones de culpabilidad* que invierten el peso de la prueba (hecho propio del art. 2329, hecho ajeno y hecho de las cosas)— se trata sistemáticamente en la **Sección 6**.

5.3.3. La antijuridicidad: ¿elemento autónomo?

Para que haya responsabilidad, el daño debe provenir de un comportamiento *objetivamente ilícito*, contrario al ordenamiento. Así se desprende del artículo 1437 (fuente de obligaciones es el "hecho que ha inferido injuria o daño") y del artículo 2284 ("si el hecho es ilícito, y cometido con intención de dañar, constituye un delito"). La ilicitud puede fundarse en la infracción de un deber legal expreso o en la transgresión del principio general de que no es lícito dañar a otro sin causa justificada (*alterum non laedere*). A diferencia del derecho penal, la responsabilidad civil **no exige tipicidad**; con todo, la ley civil describe a veces conductas que considera generadoras de responsabilidad (arts. 423, 934, 1768, entre otros), supuestos que la doctrina denomina *ilícito civil típico*.

Debate doctrinal — ¿Es la antijuridicidad un elemento autónomo?

Tesis que la niega como elemento autónomo (BARROS; doctrina nacional mayoritaria). La antijuridicidad no constituye un requisito independiente, porque se *subsume* en los demás elementos: si hay culpa o dolo es porque hay ilicitud (la culpa es la ilicitud de la conducta), y solo se indemniza el daño injusto. La ilicitud no agrega nada que no esté ya en la culpabilidad y en el daño.

Tesis que la afirma como elemento autónomo (CORRAL, RODRÍGUEZ GREZ). La ilicitud no va necesariamente unida a la culpabilidad ni al daño: *puede haber culpa sin ilicitud* (cuando opera una causal de justificación) y un daño puede causarse de manera justificada. Por ello la antijuridicidad merece tratarse separadamente, y a ella se anudan las causales de justificación. CORRAL añade que el ilícito típico cumple la función de *indicio* de la antijuridicidad, mientras RODRÍGUEZ sostiene que operaría de modo semejante a la responsabilidad objetiva.

Para el examen: sea que se la considere elemento autónomo o no, su contenido práctico se concentra en las *causales de justificación*. Quien sigue a BARROS las analiza como circunstancias que excluyen la culpa (la ilicitud); quien sigue a CORRAL, como circunstancias que excluyen la antijuridicidad. El resultado es el mismo: no hay responsabilidad.

5.3.4. Las causales de justificación

Las causales de justificación son circunstancias que excluyen la ilicitud de una conducta que, de otro modo, sería antijurídica, de manera que el daño causado no genera responsabilidad. La ley no las ha reglamentado orgánicamente; la doctrina las ha sistematizado en cuatro grupos: (a) la ejecución de actos autorizados por el derecho; (b) el consentimiento de la víctima; (c) el estado de necesidad; y (d) la legítima defensa.

Precisión — No confundir con las causales que excluyen la voluntariedad

ALESSANDRI incluía entre las "eximentes de responsabilidad" también el caso fortuito, la fuerza, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero. Pero estas no operan excluyendo la *ilicitud*, sino actuando sobre otros elementos: el caso fortuito y la fuerza suprimen la *voluntariedad* del acto (tratados en 5.1), y la culpa de la víctima o el hecho de un tercero inciden en la *causalidad* (Sección 5.4). Las verdaderas causales de justificación son las cuatro enunciadas.

a) Ejecución de actos autorizados por el derecho

Dentro de este grupo se distinguen tres situaciones: el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber legal y los actos autorizados por usos normativos.

(i) El ejercicio legítimo de un derecho. El ejercicio de un derecho elimina la ilicitud de la acción dañosa: no hay ilícito en que un restaurante se instale a media cuadra de otro y le prive de parte de su clientela —siempre que respete la libre competencia—, ni en el mero ejercicio de una acción judicial, aunque los tribunales no la

acojan. El daño así causado es un daño *autorizado*. Pero este principio tiene un límite interno decisivo: el **abuso del derecho**.

El abuso del derecho

El ejercicio de un derecho, en sí mismo legítimo, puede tornarse ilícito cuando se ejerce de manera abusiva, causando daño de modo ilegítimo. La *teoría del abuso del derecho* sostiene que el ejercicio abusivo de un derecho genera la obligación de reparar los perjuicios producidos. Su fundamento dogmático ha sido objeto de una conocida evolución:

- **Tesis negadora (PLANIOL)**. Los autores individualistas sostuvieron que el contenido del derecho es su único límite: no puede ejercerse a la vez un derecho y obrar "contra derecho", pues ello vulneraría el principio de no contradicción. Para esta postura, hablar de "abuso del derecho" es un contrasentido lógico: donde hay derecho no hay abuso, y donde hay abuso no hay derecho.
- **Tesis finalista o funcional (JOSSERAND)**. Hay abuso cuando el derecho subjetivo se ejerce contrariando su *función social y económica*, esto es, en desacuerdo con el fin para el cual fue conferido. Para determinarlo, debe indagarse en los motivos del titular o en el fin que se propuso alcanzar.
- **Tesis de la culpa (RIPERT, MAZEAUD; en Chile, ALESSANDRI)**. El abuso del derecho es, sencillamente, una *culpa* cometida en el ejercicio de ese derecho, que da lugar a responsabilidad civil conforme a las reglas generales.
- **Tesis de la buena fe (BARROS; posición mayoritaria actual)**. Existe abuso cuando el derecho se ejerce de manera *desleal*, contrariando la buena fe y las buenas costumbres. La buena fe —dice BARROS— "expresa en el derecho aquel núcleo de sentido que subyace a las normas atributivas de derechos, que se muestra en los límites que la norma no expresa, pero da por supuesto". Más allá de la buena fe, el acto se torna antijurídico.

Reconocimiento normativo. El ordenamiento contiene múltiples manifestaciones de los límites internos al ejercicio de los derechos, particularmente del derecho de propiedad: la Constitución sujeta el dominio a su *función social* (art. 19 N.º 24); el Código Civil define el dominio como la facultad de gozar y disponer arbitrariamente de la cosa "no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno" (art. 582), límite extensible a todas las cosas incorporales (art. 583); y, en el contrato de sociedad, los artículos 2110 a 2112 sancionan la renuncia hecha "de mala fe o intempestivamente" —el socio que renuncia para apropiarse de una ganancia que pertenecía a la sociedad—, supuesto típico de abuso fundado en la transgresión de la buena fe.

La jurisprudencia estima que el abuso del derecho constituye un ilícito civil que se rige por las reglas de la responsabilidad extracontractual. En un fallo de 2007, la Corte resolvió que "la doctrina del abuso del derecho asume que el ejercicio de un derecho puede ser ilícito, aunque el titular actúe dentro de los límites externos que establece el respectivo ordenamiento normativo, y solo puede ser invocada cuando el comportamiento del titular atenta contra estándares mínimos de conducta". Añadió que la jurisprudencia es constante en someter el ejercicio del derecho a las reglas de la responsabilidad civil y en **exigir dolo o culpa** para que nazca la obligación indemnizatoria, debiendo existir de parte del agente "un ánimo manifiesto de perjudicar", una evidente falta de interés o necesidad legítimos, o un actuar con desvío de los fines de la institución.

Ejemplo — Supuestos de abuso del derecho

Constituyen ejercicio abusivo, entre otros: la *acción judicial temeraria*, deducida con el solo afán de perjudicar o sin interés legítimo; la *renuncia de mala fe* del socio para apropiarse de una ganancia social (arts. 2110-2112); y las instalaciones de pura emulación —construir un muro sin utilidad propia, con el único fin de privar de luz o vista al vecino—. En todos, el titular obra dentro de los límites externos de su derecho, pero desviándose de su fin o contrariando la buena fe.

Dato de grado — Requisitos del abuso del derecho

Para que se configure el abuso del derecho deben concurrir: (1) la **titularidad de un derecho** por parte del agente (si no hay derecho, el acto es directamente ilícito, no abusivo); (2) un **daño** causado a otro con su ejercicio; y (3) una **conducta reproachable**, que la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia identifican con el dolo o la culpa, el desvío del fin de la institución o la contravención de la buena fe. Acreditados, el abuso da lugar a responsabilidad extracontractual.

(ii) **Cumplimiento de un deber legal.** Quien actúa en cumplimiento de un deber impuesto por la ley no comete ilícito alguno: tal es el caso del agente de policía que priva de libertad al detenido, o del receptor judicial que traba un embargo. Más compleja es la *observancia de órdenes de autoridad*: por regla general justifica el daño, siempre que la orden no sea *manifiestamente ilegal*. CORRAL precisa que lo determinante es el grado de coerción de la orden, esto es, si llega a suprimir la voluntariedad del subordinado (lo que rara vez ocurrirá).

(iii) **Actos autorizados por usos normativos.** Más allá de las fuentes formales, queda excluida la ilicitud cuando la conducta se ajusta a usos o prácticas comúnmente tenidos por correctos. Así, la incisión que practica el médico conforme a su *lex artis*, o las lesiones que ocasiona el futbolista en una acción violenta pero tole-

rada por las reglas del juego, no constituyen hechos ilícitos. En todos estos casos el límite está dado por los deberes de cuidado propios de cada actividad: solo la infracción de esos deberes —y no la lesión en sí— acarrea responsabilidad.

b) El consentimiento de la víctima

Aunque en sede extracontractual lo normal es que no exista relación previa entre víctima y autor, nada obsta a que medien acuerdos anticipados: autorizaciones para ejecutar un acto, o convenciones sobre responsabilidad mediante las cuales se acepta cierto nivel de riesgo (por ejemplo, la recíproca irresponsabilidad pactada por los participantes de una carrera automovilística). La existencia de tal estipulación no transforma la responsabilidad en contractual, pues no supone una obligación previa incumplida. Estas convenciones pueden eximir totalmente de la obligación de indemnizar o limitarla a cierta suma; su tratamiento detallado corresponde a la Sección 7 (cláusulas modificatorias de responsabilidad).

Cuando la víctima potencial *consiente* en la ejecución de un acto que puede dañarla, realiza un acto de disposición sujeto a límites generales: (i) la autorización no puede importar **condonación del dolo futuro**, prohibida por el artículo 1465; y (ii) no puede significar la renuncia de **derechos indisponibles** —como la vida o la integridad física— en virtud del artículo 12. Debe distinguirse, además, entre *renunciar a un derecho* y *asumir un riesgo*: solo hay disposición en el primer caso. La simple aceptación de un riesgo razonable (vuelos de prueba, experimentos con fármacos) se entiende autorizada aun respecto de bienes indisponibles; pero si la probabilidad de daño es tan alta que el riesgo excede de lo razonable, habrá un verdadero acto de disposición sobre bienes irrenunciables y la autorización no será válida. Para que la asunción del riesgo opere como justificación, el autor debe haber proporcionado a la víctima información suficiente sobre su intensidad y probabilidad.

c) El estado de necesidad

El estado de necesidad es aquel en que una persona se ve obligada a ocasionar un daño a otra para evitar uno mayor, a sí misma o a un tercero. El ejemplo jurisprudencial clásico es el de la autoridad que, para impedir la propagación de un incendio en un puerto, arroja al mar unos barriles de aguardiente. Sus **requisitos** son: (a) que el peligro que se trata de evitar no tenga su origen en una acción culpable del agente; y (b) que no existan medios inocuos o menos dañinos para conjurarlo.

El estado de necesidad se diferencia del caso fortuito en que el hecho, aunque imprevisto, *no es irresistible*: puede resistirse, pero a costa de un daño propio. Nuestra legislación civil no lo contempla expresamente (sí lo hace el art. 10 N.º 7 del Código Penal), por lo que su acogida exige asimilarlo a la ausencia de culpa. Su efecto es excluir la acción *indemnizatoria* de la víctima, pero no la acción *restitutoria*: como advierte RODRÍGUEZ GREZ, el derecho no puede amparar el enriquecimiento injusto de quien salva un bien propio con cargo a un patrimonio ajeno, de modo que subsiste el deber de compensar los daños materiales necesarios para restaurar el equilibrio entre ambos patrimonios.

d) La legítima defensa

La legítima defensa opera en el derecho civil de modo análogo al penal: actúa en legítima defensa quien ocasiona un daño obrando en defensa de su persona o de sus derechos. Requiere la concurrencia de cuatro circunstancias: (a) que la **agre-**

sión sea ilegítima; (b) que no haya mediado provocación suficiente por parte de quien se defiende; (c) que la **defensa sea proporcionada** al ataque; y (d) que el daño se haya producido *a causa* de la defensa. Concurriendo estos requisitos, el daño causado al agresor no genera responsabilidad.

5.3.5. La responsabilidad estricta u objetiva

Frente al régimen general de responsabilidad por culpa o dolo, el ordenamiento reconoce un factor de atribución diverso: la **responsabilidad estricta u objetiva**, que prescinde por completo de la conducta del sujeto, de su culpabilidad o intencionalidad, y atiende exclusivamente al daño producido y a su conexión con una actividad. Como sintetiza ORREGO, "el que crea un riesgo debe responder de él": no es el hecho culpable, sino el hecho liso y llano vinculado a una fuente de peligro, el que genera la obligación de reparar.

Fundamento: la teoría del riesgo. El fundamento de la responsabilidad objetiva es el *riesgo*. La *teoría del riesgo creado* atribuye al autor las consecuencias de los riesgos que él mismo ha introducido; la *teoría del riesgo-provecho* agrega un criterio de justicia distributiva: quien obtiene el beneficio económico de una actividad peligrosa debe soportar también sus costos (*ubi emolumentum, ibi onus*). RODRÍGUEZ GREZ subraya que el riesgo jurídicamente relevante es el provocado por el acto humano —no el derivado de la naturaleza— y que el más intenso es el riesgo *anormal, de actividad inútil y lucrativo*: aquel que altera las condiciones naturales, nace de una conducta humana, es productivamente innecesario y reporta provecho a quien lo crea.

Dato de grado — La responsabilidad objetiva es excepcional y de derecho estricto

La responsabilidad por culpa es la **regla general**; la objetiva es **excepcional** y, por ello, requiere texto legal expreso que la establezca. *No cabe su aplicación analógica*: a falta de una norma que admita un factor objetivo, la responsabilidad es subjetiva (si hay culpa) o no existe deber de reparar, debiendo la víctima soportar el daño. Adviértase, además, que aun en los regímenes objetivos la culpa puede reaparecer —no para atribuir responsabilidad, sino para *eximir* de ella—: el demandado siempre podrá probar que el daño se debió a culpa exclusiva de la víctima o de un tercero.

Casos en el Código Civil. RODRÍGUEZ GREZ identifica tres hipótesis de responsabilidad objetiva en el propio Código:

- **Animal fiero (art. 2327).** "El daño causado por un animal fiero, de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, será siempre imputable al que lo tenga, y si alegare que no le fue posible evitar el daño, no será oído." La responsabilidad pesa sobre quien *tiene* el animal (no necesariamente su dueño) y no admite excusa. Si el animal fiero reporta utilidad, en cambio, la responsabilidad vuelve a ser subjetiva.
- **Cosa que cae o se arroja de un edificio (art. 2328).** Cuando no puede identificarse al culpable, la obligación de reparar recae sobre todos los que habitan la parte del edificio de donde cayó la cosa. Es una responsabilidad objetiva subsidiaria, fundada en el amparo a la víctima, que ni siquiera exige una vinculación material concreta con el daño.

- **Provecho del dolo ajeno (art. 2316 inc. 2.º).** Quien recibe provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice, responde hasta la concurrencia de ese provecho. RODRÍGUEZ GREZ precisa que aquí la responsabilidad objetiva no se funda en el riesgo, sino en la *reparación del enriquecimiento injusto*.

Estatutos especiales. Las principales leyes que consagran fórmulas de responsabilidad objetiva en Chile son: la **Ley N.º 18.302 sobre Seguridad Nuclear** (responsabilidad del explotador por todo "accidente nuclear", canalizada exclusivamente en él y sujeta a límites de cuantía); el **Decreto Ley N.º 2.222 (Ley de Navegación)** y el convenio internacional sobre contaminación de las aguas por hidrocarburos; el **Código Aeronáutico** (daños a terceros en la superficie y a pasajeros); y la **Ley N.º 18.290 del Tránsito** (responsabilidad del propietario del vehículo). A ellos suele añadirse la responsabilidad por daño ambiental y otros regímenes sectoriales. En todos, el legislador ha preferido garantizar la reparación de la víctima frente a actividades intrínsecamente riesgosas, desplazando la exigencia de culpa.

5.4. Causalidad

El último de los elementos del régimen general de responsabilidad por culpa es la **relación de causalidad**: entre el hecho ilícito y el daño debe existir un vínculo o nexo de causa a efecto, de modo que el hecho sea *causa* del daño y el daño sea *efecto* del hecho. No basta, pues, con que el demandado haya obrado con culpa y con que la víctima haya sufrido un perjuicio: es necesario, además, que ese perjuicio sea *consecuencia* de aquella conducta. La causalidad cumple así una doble función —según la conocida formulación de BARROS—: opera como **requisito** de la responsabilidad (el hecho debe ser condición necesaria del daño) y como **límite** de ella (solo se responde de los daños que son consecuencia *directa* del ilícito, no de los meramente remotos o accidentales).

El Código Civil no reglamenta orgánicamente la causalidad, pero la supone en numerosas disposiciones: el artículo **2314** exige que el delito o cuasidelito haya "inferido daño a otro"; el artículo **2318** hace responsable al ebrio del daño "causado" por su hecho; los artículos **2319** y **2325** aluden a los "daños causados". Buena parte de la doctrina invoca además, por analogía, el artículo **1558** —propio de la responsabilidad contractual—, que limita la indemnización a los "perjuicios que fueron consecuencia inmediata y directa" del incumplimiento. La determinación del nexo causal es uno de los problemas más complejos de la disciplina, y la doctrina civil ha tomado en préstamo numerosas teorías elaboradas por la ciencia penal. Para ordenarlas, conviene distinguir **dos planos** de análisis —uno naturalístico o fáctico y otro normativo o valorativo—, tal como hoy lo postulan BARROS y CORRAL.

5.4.1. El elemento naturalístico: el hecho como condición necesaria del daño

En un primer plano, puramente fáctico, se trata de establecer si el hecho del demandado figura entre los antecedentes que materialmente produjeron el daño. La doctrina clásica resuelve esta pregunta mediante la **teoría de la equivalencia de las condiciones** (o de la *condicio sine qua non*), según la cual no es posible jerarquizar las diversas condiciones que concurren a un resultado: *todas* son equivalentes en cuanto a la causalidad. Basta, por tanto, que el hecho del autor haya sido una de las condiciones del daño para que pueda tenérselo por causa.

El método para identificar una condición es el de la **supresión mental hipotética**: se suprime imaginariamente el hecho y se examina qué habría ocurrido. Si, elimi-

nado el hecho, el daño igualmente se habría producido, el hecho no es condición del resultado; si, en cambio, suprimido el hecho el daño desaparece, el hecho es *condición sin la cual* el resultado no se habría producido y, por ende, su causa.

Ejemplo — Cadena de condiciones necesarias

Una persona sufre lesiones en un accidente de tránsito; trasladada al hospital, recibe un tratamiento médico erróneo del que sobreviene su muerte. Conforme a la equivalencia de las condiciones, tanto el accidente como el error médico son causa de la muerte, pues sin cualquiera de ellos esta no se habría producido. Frente a la víctima, cada responsable queda obligado al total del daño (solidaridad del art. 2317), sin perjuicio de la contribución a la deuda entre los coautores.

La teoría de la equivalencia ha sido muy utilizada por la jurisprudencia chilena por su **simpleza** —así, se ha resuelto que quien fallece de una gangrena sobrevenida al accidente debe ser indemnizado, porque se responde de los daños mediatos o remotos que sean consecuencia necesaria del hecho—. Sin embargo, la doctrina le formula reparos decisivos:

- **Petición de principio.** La supresión mental solo opera si ya se sabe de antemano si el factor suprimido es o no causa del resultado (objeción de ROXIN): la fórmula *presupone* aquello que pretende averiguar.
- **Causalidad acumulativa.** Cuando dos causas independientes bastan cada una para producir el resultado, la supresión de cualquiera de ellas llevaría a concluir que *ninguna* es causa, generando una impunidad inaceptable.
- **Extensión desmesurada.** Aplicada con rigor, conduce a un regreso al infinito: cualquier antecedente de la cadena podría reputarse causa (al extremo, podría imputarse un homicidio a los padres que procrearon al asesino).

Por estas razones, la doctrina moderna reconoce que la equivalencia de las condiciones sirve para *excluir* la causalidad (lo que no es condición necesaria no puede ser causa), pero es **insuficiente** para afirmarla: no distingue, entre las muchas condiciones necesarias de un daño, cuáles son jurídicamente relevantes. Para ello es preciso pasar al segundo plano de análisis.

5.4.2. El elemento normativo: la imputación objetiva del daño

En un segundo plano, valorativo, se trata de seleccionar —de entre todas las condiciones necesarias— aquella o aquellas a las que el derecho atribuye el daño como consecuencia *directa*. Aquí la doctrina ha ensayado diversas teorías que superan la mera causalidad física.

Teoría de la causa adecuada. Entre las condiciones del daño debe preferirse la que, según el *curso normal* de los acontecimientos, es generalmente idónea para producirlo. Desde la perspectiva de un observador objetivo, hay causa adecuada cuando el daño es una consecuencia *verosímil* del hecho; no la hay cuando el resultado obedece a factores casuales o extraordinarios. Su mérito es limitar la extensión de la responsabilidad; su principal crítica, que introduce en la causalidad un juicio de *previsibilidad* que es propio de la culpabilidad, confundiendo ambos elementos.

Ejemplo — Causa adecuada

Quien hiere levemente a otro responde de su muerte si la herida se infecta y deriva en una septicemia, porque ese desenlace es la consecuencia *verosímil* de una lesión mal curada. En cambio, no responde si la víctima fallece porque, durante el traslado, un rayo cae sobre la ambulancia: ese resultado es un puro azar que escapa al curso normal de los acontecimientos. Por la misma razón, quien —deseando la muerte de otro— lo convence de pasear bajo una tormenta esperando que lo fulmine un rayo, no es responsable aunque el rayo efectivamente caiga, pues morir fulminado no es la consecuencia normal de salir a caminar.

Teoría de la imputación objetiva. Desarrollada por LARENZ y ROXIN, entiende la causalidad jurídica como un problema de *imputación* medida por parámetros objetivos: solo es atribuible al autor el resultado que supone la creación de un **riesgo jurídicamente desaprobado**, superior al riesgo general de la vida que todos debemos tolerar. La creación o el mantenimiento del riesgo ordinario no puede considerarse causa del daño que de él derive.

Ejemplo — Imputación objetiva

El sobrino que, para heredar a su tío rico, le costea un viaje en avión confiando en que la aeronave se estrelle, no responde aunque el avión efectivamente caiga: viajar en avión es un *riesgo general de la vida*, no un riesgo jurídicamente desaprobado creado por él. A la inversa, sí se imputa el resultado a quien conduce a exceso de velocidad y atropella a un peatón, pues con su conducta elevó el riesgo por encima del umbral que el ordenamiento tolera.

La síntesis de la doctrina nacional. BARROS y CORRAL sostienen que la causalidad no puede resolverse desde una perspectiva ni puramente naturalística ni puramente normativa: se requiere un análisis en dos etapas. Primero, la equivalencia de las condiciones (test de la supresión mental) permite descartar lo que no es condición necesaria. Luego, para afirmar la causalidad *jurídica*, el análisis se complementa con dos criterios normativos: la **previsibilidad** del resultado y el **incremento ilícito del riesgo** ordinario de la vida. A ellos se añade, como criterio de cierre, el **fin protector de la norma**: solo se responde de los daños que la regla infringida buscaba precisamente evitar.

El daño directo: cuatro casos de BARROS

La línea que separa el daño directo (resarcible) del indirecto (no resarcible) se aprecia en estos ejemplos:

- **Contagio en el hospital.** El atropellado contrae influenza durante su internación y duplica su tiempo de inactividad. *No* hay responsabilidad del autor por ese mayor daño: el accidente no aumentó la disposición a contraer la enfermedad (no es causa adecuada ni incrementó el riesgo).
- **El bocinazo.** Un bocinazo provoca un infarto a un conductor de edad avanzada. *No* hay responsabilidad: la debilidad particular de la víctima opera como circunstancia exorbitante que excede el riesgo creado por la acción.
- **La ambulancia.** La ambulancia que traslada al herido choca y le causa nuevos daños. *Sí* hay responsabilidad del autor del accidente original: el traslado de urgencia queda comprendido en el ámbito de riesgo creado por su conducta.
- **El atochamiento.** El mal estado de un camino produce un choque y un gran atochamiento, en el que un empresario pierde un negocio. El responsable debe los daños de las víctimas inmediatas, pero *no* la pérdida del negocio: ese perjuicio es ajeno al fin protector de la norma sobre conservación de caminos.

5.4.3. Pluralidad de causas

Con frecuencia el daño no obedece a una sola causa, sino a la concurrencia de varias. La doctrina distingue las principales hipótesis:

- **Pluralidad de responsables (coautoría).** Cuando el daño se debe a la intervención de dos o más personas —sea que ejecuten un mismo hecho, sea que cada una ejecute un hecho que contribuye al resultado—, rige la regla de **solidaridad** del artículo **2317**: todos responden frente a la víctima por el total del perjuicio, sin perjuicio de la contribución que entre ellos corresponda según su participación.
- **Hecho de la propia víctima.** Si la víctima se expuso imprudentemente al daño, su conducta concurre causalmente con la del autor. El artículo **2330** ordena entonces *reducir* proporcionalmente la indemnización ("la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente"). No se trata de una causal de exoneración total —salvo que la culpa de la víctima sea la causa *exclusiva* del daño, caso en que se rompe el nexo respecto del demandado—, sino de un reparto del peso del daño en función de la contribución causal de cada uno.
- **Hecho de un tercero.** Si en la producción del daño intervino, como condición necesaria, el hecho ilícito de un tercero, rige también la solidaridad del artículo **2317** frente a la víctima, con la consiguiente acción de reembolso entre los responsables.
- **Caso fortuito o fuerza mayor.** Cuando el daño se debe a un hecho externo, imprevisible e irresistible, ajeno a la conducta del demandado, falta el nexo causal entre el hecho de este y el perjuicio: el caso fortuito *interrumpe* la cadena causal y exonera de responsabilidad (sin perjuicio de los regímenes de responsabilidad estricta, donde por excepción no siempre exonera).

Dato de grado — Prueba y control de la causalidad en casación

La existencia del vínculo causal debe ser **probada por la víctima**, conforme a las reglas generales (art. 1698), y admite toda clase de medios, incluidas las presunciones. La causalidad presenta una doble naturaleza para efectos del recurso de casación, en paralelo con lo visto a propósito de la culpa: el establecimiento de los hechos materiales que conforman el nexo (la causalidad *natural*) es cuestión de hecho privativa de los jueces del fondo, no revisable en casación; en cambio, la **calificación jurídica** de si el daño es "directo" —esto es, la causalidad *normativa*— es cuestión de derecho y, como tal, queda sometida al control de la Corte Suprema.

PAUSA — COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado la **Sección 5 — Requisitos de la responsabilidad extracontractual**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

6. PRESUNCIONES DE RESPONSABILIDAD

6.1. Consideraciones generales

Como se vio al tratar la prueba de la culpa (subsección 5.3.2), la regla general es que la culpa debe ser **probada por quien la alega** (art. 1698). Esta regla coloca a menudo a la víctima en una grave desventaja estratégica: por lo común carece de los instrumentos para demostrar que el autor del daño no empleó la diligencia debida y, en los casos más complejos, ni siquiera está en condiciones de precisar cuál era el deber de cuidado infringido. Para corregir esa desigualdad, el Código Civil establece **presunciones de culpabilidad**, cuyo efecto es *invertir el peso de la prueba* en favor de la víctima.

Es capital comprender el alcance de estas presunciones: **no alteran la naturaleza subjetiva** de la responsabilidad, que sigue fundada en la culpa o el dolo; solo modifican la *posición estratégica* de las partes frente a la prueba. Acreditada la presunción, corresponde a la víctima probar el **hecho**, el **daño** y la **relación causal**; y al demandado, para exonerarse, probar su **diligencia** —o la concurrencia de fuerza mayor o de una causal de justificación—. No se trata, pues, de responsabilidad objetiva: la culpa sigue siendo el fundamento, solo que se la presume.

El Código Civil contempla tres categorías de presunciones de culpabilidad, según el origen del daño:

- **Por el hecho propio** —artículo 2329—, cuando el daño proviene de una conducta que, por su naturaleza, normalmente no ocurre sin negligencia.
- **Por el hecho ajeno** —artículos 2320, 2321 y 2322—, cuando el daño lo causa una persona que estaba bajo la dependencia o cuidado del demandado.

- **Por el hecho de las cosas** —artículos **2323**, **2324**, **2326**, **2327** y **2328**—, cuando el daño proviene de un edificio, un animal o una cosa de que el demandado es dueño o se sirve.

Dato de grado — Casi todas admiten prueba en contrario, salvo dos

Por regla general las presunciones de culpabilidad son **simplemente legales**: el demandado puede destruirlas probando su diligencia. Hay, sin embargo, dos hipótesis en que la ley *no* admite la excusa de diligencia, acercándose a una responsabilidad estricta: la responsabilidad de los **padres** por los delitos o cuasidelitos de los hijos que provengan de su mala educación o de hábitos viciosos (art. **2321**), y la responsabilidad por el **animal fiero** del que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio (art. **2327**).

6.2. Presunción de culpabilidad por el hecho propio (art. 2329)

El artículo **2329** dispone que "por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta", y agrega tres ejemplos: el disparo imprudente de un arma de fuego; la remoción de las losas de una acequia o cañería sin las precauciones necesarias; y la mantención en mal estado de un puente o acueducto que cruza un camino.

Inicialmente la doctrina vio en esta norma una simple repetición del artículo **2314**. Fue DUCCI quien primero sostuvo que el artículo 2329 encierra una **presunción de culpabilidad** cuando el daño proviene de actividades caracterizadas por su *peligrosidad*. ALESSANDRI amplió luego el criterio: el precepto presume la culpa cuando el daño deriva "de un hecho que, por su naturaleza o por las circunstancias en que se realizó, es susceptible de atribuirse a culpa o dolo del agente". El ejemplo emblemático —que el examen suele exigir— es el **choque de trenes**: como "los trenes deben movilizarse en condiciones de no chocar", el solo hecho del choque revela negligencia y permite presumir la culpa.

La doctrina ofrece cuatro **fundamentos** para esta lectura:

- **Exegético.** La ubicación del artículo 2329 —inmediatamente después de las presunciones por el hecho ajeno (2320, 2322) y por el hecho de las cosas (2323-2328)— y su encabezado ("por regla general, todo daño...") revelan que el legislador quiso establecer una *regla de clausura* del sistema de presunciones, comprensiva de los demás casos análogos. Es la única forma de no reducir la norma a una repetición inútil del artículo 2314.
- **De texto.** La norma no se refiere a todo daño *causado por* negligencia, sino a todo daño que "pueda imputarse" a negligencia: alude a una conducta que por sí misma *tiende* a ser negligente, antes de toda prueba. Mientras no se demuestre lo contrario, pesa sobre el autor la obligación de indemnizar.
- **De experiencia.** Se atribuye responsabilidad cuando el sentido común indica que un daño producido en tales circunstancias se debe usualmente a culpa. Es la idea que el derecho anglosajón expresa con la fórmula *res ipsa loquitur* ("la cosa habla por sí misma").

- **De justicia correctiva.** A menudo la presunción es el único camino practicable para construir la responsabilidad, sobre todo en accidentes derivados de procesos industriales o de servicios complejos, donde la víctima no puede identificar el acto u omisión concretos que los provocaron (piénsese en los productos defectuosos —fármacos, alimentos—, a falta de un régimen de responsabilidad estricta).

La jurisprudencia coincide en que la enumeración del artículo 2329 **no es taxativa** y ha tenido por reveladores de negligencia, entre otros, los derrumbes en la demolición de un edificio, la muerte de un transeúnte por una línea eléctrica tendida en condiciones peligrosas, el pozo descubierto sin señalización y el volcamiento de un carro de ferrocarril por el mal estado de la vía.

Para ordenar su aplicación, BOETSCH identifica tres **grupos de casos**: (i) la *peligrosidad de la acción* —quien actúa en ámbitos riesgosos debe adoptar todos los resguardos; aquí se inscribe el choque de trenes—; (ii) el *control de los hechos* por el demandado —cuando este, a cargo de un proceso productivo complejo, está en mejor posición que la víctima para procurarse la prueba—; y (iii) el *rol de la experiencia* —cuando cierto tipo de accidentes se deben más frecuentemente a negligencia que a caso fortuito—.

EL CASO EMBLEMÁTICO — EL "CHOQUE DE TRENES"

Si dos trenes colisionan, el curso normal de los acontecimientos revela que hubo negligencia, porque "los trenes deben movilizarse en condiciones de no chocar". Producido el choque, la víctima no necesita probar en qué consistió la falta de cuidado del operador: le basta acreditar el hecho (la colisión), el daño y el nexo causal, y se presume la culpa. Corresponderá entonces a la empresa ferroviaria demostrar su diligencia o un caso fortuito para exonerarse. Es la formulación clásica de la presunción del artículo 2329 y la manifestación más nítida del principio *res ipsa loquitur* en nuestro derecho.

6.3. Presunción de culpabilidad por el hecho ajeno (arts. 2320-2322)

El artículo **2320** sienta el principio: "toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado". No se trata de responder por un hecho verdaderamente ajeno, sino de una **responsabilidad por el hecho propio presunto**: la ley presume que quien tiene a otro bajo su dependencia o cuidado incurrió en *culpa in vigilando* (falta de vigilancia) o *culpa in eligendo* (falta de cuidado en la elección). De ahí que se la conozca también como responsabilidad por el hecho ajeno, indirecta o refleja.

Requisitos. Para que opere se exige: (a) un *vínculo de subordinación o dependencia* entre el autor del daño y el tercero responsable; (b) que *ambos sean capaces* de delito o cuasidelito —si el autor es incapaz, no hay responsabilidad por el hecho ajeno, sino la del guardián del artículo 2319 (véase 5.1.4)—; (c) que el subordinado haya cometido un *hecho ilícito*, el cual debe probar la víctima; y (d), tratándose de dependientes, que el daño se haya causado *en ejercicio de sus funciones*.

El artículo 2320 enuncia diversos casos: el **padre —y, a falta de este, la madre—** responde por los hijos menores que habitan en la misma casa; el **tutor o curador**,

por el pupilo que vive bajo su dependencia; los **jefes de colegios y escuelas**, por los discípulos mientras están a su cuidado; y los **artesanos y empresarios**, por el hecho de sus aprendices o dependientes. La enumeración no es taxativa: el principio alcanza a toda relación de cuidado o dependencia.

La exculpación (art. 2320, inc. final). Como toda presunción simplemente legal, esta admite prueba en contrario: la responsabilidad cesa si quien la soporta prueba que "con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho". El tercero se libera, pues, acreditando su propia diligencia.

Atención — Dos reglas especiales: arts. 2321 y 2322

- **Art. 2321 — Responsabilidad agravada de los padres.** Los padres responden *siempre* de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, "y que conocidamente provengan de mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir". Esta es una presunción de derecho que **no admite la excusa de diligencia** del artículo 2320: probado que el hecho provino de la mala educación o de los hábitos viciosos, la responsabilidad del padre es ineludible.
- **Art. 2322 — Amos y criados.** Los amos responden de la conducta de sus criados o sirvientes "en el ejercicio de sus respectivas funciones". Aquí la exculpación es posible, pero más exigente: el amo se libera si prueba que los criados "han ejercido sus funciones de un modo impropio que [él] no tenía medio de prever o impedir, empleando el cuidado ordinario y la autoridad competente".

Acción de reembolso (art. 2325). El tercero que ha pagado la indemnización tiene derecho a *repetir* contra el autor del daño, siempre que este sea capaz de delito o cuasidelito (art. 2319) y haya obrado sin orden de aquel. La obligación pesa, en definitiva, sobre el autor capaz; el tercero responde frente a la víctima, pero no soporta el peso final de la deuda. (Recuérdese el contraste con el guardián del incapaz del art. 2319, que sí soporta definitivamente la indemnización: véase el recuadro de la subsección 5.1.4.)

La responsabilidad del empresario por sus dependientes (ZELAYA)

La responsabilidad del empresario por el hecho de sus dependientes (art. 2320) es hoy la hipótesis de mayor relevancia práctica. La doctrina especializada —ZELAYA— ha mostrado una marcada **tendencia a la objetivación**: la jurisprudencia exige una diligencia tan estricta en la organización de la empresa que, en los hechos, la exculpación resulta casi imposible, aproximando esta responsabilidad a una *responsabilidad vicaria* o por el riesgo de la actividad empresarial. A ello contribuye la noción amplia de "ejercicio de las funciones": basta que la actividad del dependiente esté ligada al ámbito de la empresa, aunque haya excedido sus instrucciones concretas.

6.4. Presunción de culpabilidad por el hecho de las cosas (arts. 2323-2328)

El tercer grupo presume la culpa del dueño o de quien se sirve de una cosa que ha causado daño. A diferencia del derecho comparado, el Código no consagra un principio general de responsabilidad por el hecho de las cosas, sino casos específicos:

a) Ruina de edificios (arts. 2323 y 2324). El dueño de un edificio responde de los daños que ocasione su *ruina* cuando esta proviene de haber omitido las reparaciones necesarias o de haber faltado al cuidado de un buen padre de familia (art. 2323). Si la ruina proviene de un *vicio de construcción*, se aplica el artículo 2324, que remite a la regla 3.ª del artículo 2003: responde el empresario constructor durante el plazo legal de garantía.

b) Daño causado por animales (arts. 2326 y 2327). El dueño de un animal —o quien se sirve de él— responde de los daños causados por este, aun después de que se haya soltado o extraviado; podrá exonerarse probando que el daño no se debió a su culpa ni a la de su dependiente (art. 2326). Pero el artículo 2327 contiene una regla más severa para el *animal fiero* del que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio: aquí la responsabilidad es **estricta** —"si alegare que no le fue posible evitar el daño, no será oído"—, sin admitir excusa de diligencia.

c) Cosa que cae o se arroja de un edificio (art. 2328). El daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio es imputable a *todas las personas que habitan esa parte*, dividiéndose la indemnización entre ellas a prorrata, a menos que se pruebe que el hecho se debió a la culpa o mala intención de una sola, caso en que solo esta responde.

Dato de grado — No todo el "hecho de las cosas" es presunción de culpa

Conviene precisar, siguiendo a BARROS, que algunas de estas hipótesis no son verdaderas presunciones de culpa, sino casos de **responsabilidad estricta** de origen arcaico: así, el animal fiero del artículo 2327 y la primera parte del artículo 2328 no admiten la excusa de diligencia. En cambio, la ruina de edificios (2323) y el daño causado por animales domésticos (2326) son auténticas presunciones de culpabilidad, que el demandado puede destruir acreditando su diligencia.

PAUSA — COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado la **Sección 6 — Presunciones de responsabilidad**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

7. CLÁUSULAS MODIFICATORIAS O EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

7.1. Concepto y admisibilidad

Las **cláusulas o convenciones sobre responsabilidad** son acuerdos celebrados *antes* de que se produzca el daño, por los cuales las partes alteran el régimen legal de la responsabilidad extracontractual: lo suprimen, lo limitan o lo agravan. Constituyen una manifestación de la autonomía de la voluntad operando sobre un terreno que, de no mediar pacto, se regiría por las reglas de los artículos 2314 y siguientes.

En sede extracontractual estas convenciones son **excepcionales**, porque entre el potencial autor del daño y la eventual víctima no suele existir una relación previa —los encuentros son, por regla general, casuales—. Solo cabe pactarlas cuando el riesgo y las potenciales víctimas son *identificables a priori* y se justifica el costo de negociar: así, entre vecinos respecto de los daños de una industria, entre los participantes de una competencia automovilística, o respecto de actividades intrínsecamente riesgosas. Como observa BARROS, una línea aérea no puede en la práctica negociar con todos quienes podrían resultar dañados en tierra; por eso la regulación contractual de los riesgos es marginal y las reglas legales conservan su carácter de estatuto general.

Dos precisiones importantes: **la existencia de una convención sobre responsabilidad no transforma a esta en contractual** —pues supone una obligación de no dañar que es previa al pacto y de fuente legal— (BOETSCH); y, en principio, **no hay impedimento para que el contrato sustituya a las reglas extracontractuales**, siempre que se respeten los límites de orden público (BARROS).

7.2. Clases de cláusulas

Atendiendo a su efecto, se distinguen tres clases:

- **Cláusulas exoneratorias o eximentes.** Liberan al potencial autor de *toda* obligación de indemnizar.
- **Cláusulas limitativas.** No suprimen la responsabilidad, pero la *restringen*: fijan un tope de cuantía (una suma determinada), excluyen ciertos rubros de daño, o alteran el régimen probatorio.
- **Cláusulas agravantes.** *Aumentan* la responsabilidad del agente más allá de lo que dispondría la ley —por ejemplo, haciéndolo responder incluso del caso fortuito—. No plantean problemas de validez, pues nadie resulta perjudicado en sus derechos indisponibles.

7.3. Límites de validez

Las cláusulas que *exoneran* o *limitan* la responsabilidad encuentran dos límites infranqueables, derivados de las reglas generales sobre el objeto de los actos jurídicos:

- **No pueden condonar el dolo futuro** (art. 1465): "la condonación del dolo futuro no vale". Una cláusula que exima de responsabilidad por el daño causado dolosamente adolece de objeto ilícito y es nula. Y como el artículo 44 asimila la **culpa grave al dolo**, la prohibición se extiende a la culpa lata: tampoco puede exonerarse anticipadamente de ella.
- **No pueden disponer de derechos irrenunciables** (art. 12): los bienes de la personalidad —la vida, la integridad física y psíquica, la salud— están fuera del comercio y no son objeto de renuncia. Por ello, las cláusulas que pretendan eximir de responsabilidad por el *daño a las personas* son nulas. En la práctica, las convenciones exoneratorias o limitativas solo valen respecto del **daño patrimonial recaído sobre las cosas**.

Renunciar a un derecho vs. asumir un riesgo razonable

BOETSCH distingue dos situaciones que reciben tratamiento diverso. Cuando la víctima *renuncia a un derecho*, hay un acto de disposición sujeto a los límites anteriores. Pero cuando solo *asume un riesgo razonable*, el acto se entiende autorizado aun si recae sobre bienes indisponibles: así ocurre con quien realiza vuelos de prueba o participa en un experimento farmacológico. La frontera está en la magnitud del riesgo: si la probabilidad de daño es tan alta que el riesgo excede lo razonable, ya no hay simple asunción de riesgo, sino un verdadero acto de disposición sobre bienes irrenunciables, y la autorización no es válida. En todo caso, para que la aceptación del riesgo opere se requiere que el autor haya entregado a la víctima **información suficiente** sobre su intensidad y probabilidad, conforme a las exigencias de la buena fe.

Atención — Contratos de adhesión y consumidores

En los contratos por adhesión la libertad para pactar exoneraciones está fuertemente restringida. La Ley N.º 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores tiene por **no escritas** las cláusulas que limiten la responsabilidad del proveedor frente al consumidor, en especial las que excluyen la reparación de los daños a la persona. La tendencia legislativa y jurisprudencial es, pues, a mirar con desconfianza estas estipulaciones cuando hay desequilibrio entre las partes.

7.4. Distinciones necesarias

a) **Con el consentimiento de la víctima como causal de justificación.** La aceptación de riesgos tratada entre las causales de justificación (subsección 5.3.4) y estas convenciones comparten fundamento, pero se distinguen: la cláusula es un *acuerdo previo* que modula el régimen de responsabilidad, mientras que el consentimiento opera como justificante que excluye la ilicitud del acto concreto.

b) **Con la renuncia o transacción posteriores al daño.** Cosa enteramente distinta es que, *una vez producido* el hecho ilícito, la víctima renuncie a la indemnización, la componga con el responsable o transija con él. Estos actos son plenamente válidos: no condonan un dolo *futuro*, sino uno ya ocurrido, y no comercian con la personalidad humana, sino con un efecto puramente patrimonial —la indemnización ya devengada— (BOETSCH). La prohibición del artículo 1465 mira solo hacia el futuro.

Dato de grado — Validez de las cláusulas, en síntesis

- **Válidas:** las cláusulas *agravantes*; las exoneratorias o limitativas referidas al *daño patrimonial sobre las cosas*; la simple asunción de un riesgo razonable e informado; la renuncia o transacción *posteriores* al daño.
- **Nulas:** las que condonan el *dolo o la culpa grave* futuros (art. 1465 en relación con el art. 44); las que eximen del *daño a las personas* (art. 12); y las cláusulas limitativas en contratos de adhesión que la ley del consumidor tiene por no escritas.

PAUSA — COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado la **Sección 7 — Cláusulas modificatorias o eximentes de responsabilidad**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

8. EL PROBLEMA DE LA CONCURRENCIA DE RESPONSABILIDADES

8.1. Planteamiento del problema

El problema del "cúmulo" de responsabilidades se presenta cuando **un mismo hecho** reúne, a la vez, los caracteres de un *incumplimiento contractual* y de un *hecho ilícito extracontractual*. Para que ello ocurra deben concurrir dos condiciones: que entre el autor del daño y la víctima exista un **contrato previo**, y que la conducta dañosa infrinja simultáneamente un deber emanado de ese contrato y el deber general de no dañar a otro (*alterum non laedere*). Son casos típicos el del pasajero lesionado en el transporte, el del paciente dañado por su médico, o el del arrendatario perjudicado por el mal estado de la cosa arrendada.

La denominación "cúmulo" es equívoca, pues nadie pretende *acumular* ambas responsabilidades para cobrar dos veces el mismo daño —lo que importaría un enriquecimiento sin causa—. La pregunta real es de **opción**: ¿puede la víctima *elegir* el estatuto bajo el cual demanda —el contractual o el extracontractual—, prescindiendo del contrato para acogerse al régimen que le resulte más favorable? Por eso es preferible hablar de *concurso* u *opción* de responsabilidades.

DOMÍNGUEZ HIDALGO afina la terminología y propone abandonar derechamente la voz «cúmulo». *Cúmulo* significa *suma*, y lo que el derecho chileno prohíbe es que la víctima ejerza dos acciones y obtenga dos reparaciones por un mismo perjuicio, para evitar el enriquecimiento sin causa. La *concurrency*, en cambio, designa una construcción diversa: la posibilidad de que la víctima *acumule los aspectos más ventajosos* de uno y otro estatuto —por ejemplo, la presunción de culpa propia del régimen contractual junto con la mayor extensión del daño indemnizable del extracontractual—, no para cobrar dos veces, sino para configurar una sola

pretensión más favorable. De ahí que la denominación correcta sea *concurrentia* o *concurso* de responsabilidades, y no cúmulo.

¿Cuándo hay verdadera concurrentia? No todo daño ocurrido entre partes ligadas por un contrato plantea el problema. DOMÍNGUEZ HIDALGO ofrece cuatro reglas de delimitación:

- **No hay concurrentia cuando el contrato fue solo la *ocasión* del daño.** Si el perjuicio no proviene del incumplimiento de un deber contractual, sino de actos externos al contrato producidos «con ocasión» de él, la existencia del vínculo no basta para calificar el daño como contractual. La precisión es especialmente relevante para el *daño moral*, que a menudo se produce al margen de los deberes propiamente pactados.
- **No hay concurrentia cuando el daño recae en bienes o intereses de *terceros*.** Las reglas contractuales solo reparan los perjuicios producidos entre los co-contratantes; si el incumplimiento daña a un tercero, se aplican sin más las reglas extracontractuales.
- **Sí hay concurrentia cuando el daño del incumplimiento es, a la vez, un ilícito extracontractual.** Son los casos fronterizos en que un mismo hecho admite ambos conjuntos de reglas: típicamente, los daños de la *culpa in contrahendo* (la mal llamada responsabilidad precontractual) o postcontractual, y los producidos en bienes de la persona —vida, integridad, salud— en los contratos de transporte, de trabajo o de prestación de servicios médicos, donde el daño moral suele calificarse de fronterizo.
- **La concurrentia supone siempre un *beneficio* para la víctima.** Solo la hay cuando, al excluir el régimen contractual naturalmente aplicable, la víctima *mejora* su posición; de lo contrario, la discusión carece de objeto práctico.

8.2. Por qué importa la calificación

El interés práctico de la cuestión radica en que ambos estatutos difieren en aspectos sensibles, de modo que a la víctima puede convenirle uno u otro según el caso:

- **Prueba de la culpa:** en sede contractual la culpa del deudor se *presume* (art. 1547); en sede extracontractual debe probarla la víctima (regla general).
- **Prescripción:** la acción extracontractual prescribe en *cuatro* años (art. 2332); la contractual, en el plazo general de *cinco* años (art. 2515).
- **Extensión del daño:** en sede contractual solo se responde de los perjuicios previstos, salvo dolo o culpa grave (art. 1558); en sede extracontractual se reparan los previstos e imprevistos.
- **Graduación de la culpa, constitución en mora y solidaridad** también obedecen a reglas distintas en uno y otro régimen.

Según cuál de estas diferencias esté en juego, la víctima tendrá incentivo para "saltar" del contrato a la responsabilidad aquiliana (o a la inversa). De ahí la importancia de definir si esa opción está permitida.

8.3. Las posiciones doctrinales

a) **Tesis de la no opción o no cúmulo (mayoritaria).** Encabezada por ALESSANDRI —y conocida también como *teoría de la absorción* o de la *incompatibilidad de acciones*—, sostiene que, existiendo un contrato, la víctima *debe* demandar confor-

me al estatuto **contractual** y no puede optar por el extracontractual. Sus fundamentos: el contrato es una ley para las partes (art. **1545**) y, en virtud de su efecto obligatorio, las reglas que las partes se dieron deben prevalecer; admitir la opción permitiría a la víctima desentenderse de las estipulaciones libremente pactadas (plazos, limitaciones, exoneraciones), defraudando el régimen contractual. Esta es la posición dominante en la doctrina y la jurisprudencia chilenas.

La misma tesis reconoce, sin embargo, **dos excepciones** en que la opción sí se admite:

- Cuando **las partes lo han convenido** expresamente, autorizando a la víctima para recurrir al estatuto extracontractual.
- Cuando el incumplimiento contractual constituye, **además, un delito o cuasidelito penal** (un ilícito tipificado): en tal caso la jurisprudencia admite que la víctima ejerza la acción civil extracontractual derivada del delito.

Ejemplo — Qué está en juego en la opción

Un paciente es intervenido por el cirujano con quien celebró un contrato de prestación de servicios médicos y, por una negligencia en el quirófano, sufre una lesión. Ese mismo descuido infringe a la vez el contrato —la *lex artis* y el deber de seguridad que de él emanan— y el deber general de no dañar a otro. ¿Qué le conviene a la víctima? Si demanda en sede **contractual**, la culpa del médico se *presume* (art. **1547**) y dispone de un plazo de prescripción más largo (cinco años); si demanda en sede **extracontractual**, deberá probar la culpa, pero accede sin discusión a la reparación del daño moral y a la solidaridad cuando los responsables son varios (art. **2317**). La pregunta del cúmulo es, justamente, si la víctima puede *elegir* el estatuto que reúna a su favor las ventajas de uno y otro.

b) Tesis de la opción (minoritaria). Sostiene que la víctima puede elegir libremente entre ambas acciones, porque las dos protegen un mismo interés y nada impide invocar el deber general de no dañar aun mediando contrato. Se apoya en la idea de un *concurso de normas* que el titular puede hacer valer a su conveniencia. Esta posición es minoritaria en Chile.

c) Tesis intermedia (CORRAL). Una posición de equilibrio admite el concurso cuando, *prescindiendo del contrato*, el daño igualmente sería indemnizable a título extracontractual por infringir el deber general de no dañar (*neminem laedere*); y no solo cuando el hecho es penalmente sancionable, sino también cuando el ilícito lo es por normas civiles o contravencionales. Con todo, el cúmulo no será admisible —y primará el régimen contractual— cuando las partes expresamente lo hayan excluido, o cuando el sometimiento a la distribución de riesgos prevista en el contrato emane de su naturaleza o del principio de buena fe.

La tesis mayoritaria cuenta con respaldo constante. La Corte Suprema ha resuelto que «como regla general, el cúmulo de responsabilidades no es aceptable, porque ello significaría desconocer la ley del contrato; sin embargo, excepcionalmente cabe admitirlo cuando el hecho violatorio de las obligaciones contractuales sea al mismo tiempo constitutivo de un delito o cuasidelito penal, o cuando expresamente se hubiere pactado» (CS, 18 de abril de 1950) —fallo que condensa, a la vez, la regla y sus dos excepciones—. En la misma línea, ha calificado de «inaceptable» demandar perjuicios provenientes de ambos estatutos, pues importaría «solicitar una doble indemnización por un mismo hecho» y un enriquecimiento sin causa (CS, 3 de julio de 1951).

Como contrapunto, un antiguo fallo pareció admitir el cruce de estatutos: en un accidente de ferrocarril que causó la muerte de un pasajero, concedió la indemnización conforme a las normas extracontractuales pero *aplicando la presunción de culpa* propia de las obligaciones contractuales (CS, 13 de diciembre de 1920), solución que la doctrina mira como un caso aislado y, en rigor, contrario a la regla de la no opción.

La síntesis de DOMÍNGUEZ HIDALGO. La profesora toma partido por la *tesis de la incompatibilidad* —la absorción—, que estima la respuesta **más correcta mientras se mantenga un sistema dualista** de responsabilidad: resulta incoherente construir una responsabilidad dividida en dos especies y, a la vez, permitir que la víctima se desentienda del régimen resarcitorio que le corresponde con el solo pretexto de mejorar su posición frente al daño. La opción se acepta, según la autora, únicamente en dos hipótesis: (i) cuando las partes han convenido expresamente conceder al acreedor esa facultad; y (ii) cuando la infracción contractual es a la vez constitutiva de un *delito penal*.

Los matices de la excepción penal (arts. 59 y 108 del Código Procesal Penal). La segunda hipótesis —el ilícito que es a la vez penal— exige precisiones que la reforma procesal penal tornó ineludibles. El artículo 59 del Código Procesal Penal solo permite ejercer la acción civil reparatoria en sede penal a la *víctima*, entendida como «el ofendido por el delito» (art. 108). De ello se sigue que: (i) la opción cabe únicamente al **ofendido directo**, y no a las víctimas por repercusión o rebote, que *siempre* deben demandar en sede civil; (ii) los **herederos**, por la continuación de la persona del causante, pueden accionar en sede penal, pero la jurisprudencia limita esa posibilidad a la reparación del daño *material*, no del moral; y (iii) la opción no procede contra los **terceros civilmente responsables**, pues en sede penal la víctima solo puede accionar respecto del imputado.

La teoría del concurso de normas. Frente a la incompatibilidad, otra corriente propone resolver el problema por la vía del *concurso de normas*: calificar la acción —como contractual o extracontractual— es tarea del juez en virtud del principio *iura novit curia* («el juez conoce el derecho»), de modo que la calificación no integra las cargas del actor, a quien basta exponer los hechos y formular su pretensión. Sus detractores objetan que ello compromete el **debido proceso**: el demandado se defiende de la acción deducida con todos sus elementos y consecuencias, y que el juez altere esa calificación podría dejarlo en indefensión.

Más allá de la solución vigente, DOMÍNGUEZ HIDALGO ordena en cuatro alternativas las salidas posibles al problema, cuya elección depende de cuán justificadas estén las diferencias de régimen resarcitorio:

- **Aproximar los regímenes** contractual y extracontractual, manteniendo el rechazo a la opción (modelo francés).
- **Permitir la opción** para evitar las injusticias que derivan de la diferencia de régimen (modelo español o italiano).
- Acoger la **teoría del concurso de normas** (modelo alemán y algunas sentencias españolas).
- **Superar el dualismo** por la unificación de regímenes, estableciendo un único estatuto resarcitorio con prescindencia del origen del daño —como ya ocurre, sectorialmente, en la responsabilidad por productos defectuosos, la del transportista aéreo o la del daño ambiental—.

La autora concluye que, antes de cualquier giro jurisprudencial, es preciso definir si se defiende o no la subsistencia de dos regímenes de responsabilidad: la respuesta al cúmulo es, en último término, tributaria de esa decisión de fondo.

Dato de grado — Cómo responder la pregunta del cúmulo

La pregunta clásica de examen tiene tres pasos: **(1)** ¿cuándo se produce la concurrencia? → cuando un mismo hecho es a la vez incumplimiento contractual e ilícito extracontractual, existiendo contrato previo entre las partes. **(2)** ¿puede la víctima optar? → la regla mayoritaria (ALESSANDRI) es que *no*: debe estarse al estatuto contractual. **(3)** ¿excepciones? → sí: (i) acuerdo de las partes; (ii) que el incumplimiento configure además un ilícito penal. Para sumar matices, menciona la tesis intermedia de CORRAL (procede el concurso siempre que el daño sea igualmente indemnizable a título extracontractual). Conviene cerrar señalando *por qué* importa: prescripción, prueba de la culpa y extensión del daño difieren entre ambos regímenes (cuadro comparativo de la Sección 4). Para una respuesta de excelencia, distingue —con DOMÍNGUEZ HIDALGO— la *concurrencia* (acumular los aspectos ventajosos de ambos estatutos en una sola pretensión) del *cúmulo* (la suma de dos reparaciones, que está prohibida), y observa que el rechazo a la opción es la respuesta coherente mientras subsista el dualismo de regímenes.

8.4. No confundir: cúmulo de responsabilidades y cúmulo de indemnizaciones

Cuestión enteramente distinta —pese a la semejanza del nombre— es el **cúmulo de indemnizaciones**: el problema de si la víctima que ya obtuvo de un *tercero ajeno* al hecho ilícito una reparación del daño (por ejemplo, de una compañía aseguradora o de un organismo de seguridad social) puede, además, exigir la indemnización al autor del daño. La solución mayoritaria —explica BOETSCH— es que, si esos beneficios *tienden a reparar el mismo daño*, este se extingue y no puede reclamarse de nuevo, pues lo contrario importaría un enriquecimiento sin causa. En tal caso, la aseguradora que pagó se **subroga** en los derechos de la víctima para repetir contra el autor del daño. Mientras el cúmulo de *responsabilidades* mira a la elección del estatuto, el cúmulo de *indemnizaciones* mira a evitar la doble repara-

ción de un mismo perjuicio. A la inversa, *sí* cabe acumular la indemnización del responsable con la prestación recibida de un tercero cuando esta no tiene por objeto reparar el daño —como un seguro de personas o de vida contratado por la propia víctima—, pues no sería equitativo que el autor del perjuicio se beneficiara de una prestación ganada por la previsión de aquella (DOMÍNGUEZ HIDALGO).

PAUSA — COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado la **Sección 8 — El problema de la concurrencia de responsabilidades**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

9. LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

Reunidos los elementos del hecho ilícito, nace para la víctima una **acción** destinada a obtener la reparación del daño. Esta última sección examina esa acción desde el punto de vista procesal y sustantivo: qué acciones nacen del daño, quién puede ejercerlas (legitimación activa), contra quién se dirigen (legitimación pasiva), cómo opera la solidaridad cuando los responsables son varios, ante qué tribunal se ventila y, finalmente, cómo se extingue —con especial atención a la prescripción, que concentra una de las discusiones más vivas de la materia—.

9.1. Las acciones que nacen del daño

El daño es de la esencia de la responsabilidad civil; por ello, las acciones que de él surgen tienen por objeto, precisamente, indemnizarlo o removerlo. Conviene distinguir tres grupos:

- **La acción indemnizatoria.** Es la más frecuente. Persigue la *reparación por equivalencia*: una suma de dinero que compense el daño sufrido. Es una acción **personal, mueble, patrimonial y transmisible** (BARROS).
- **Las acciones preventivas o de remoción.** El Código permite también precaver un daño contingente o hacer cesar uno actual: la *denuncia de obra ruinosa* entre las acciones posesorias (art. **932**), una acción específica para la cosa que amenaza caer de un edificio (art. **2328** inc. 2.º) y una acción genérica de daño contingente (art. **2333**). Se tramitan en procedimiento sumario y deben interpretarse de manera extensiva.
- **La acción constitucional de protección.** En la práctica ha sustituido en buena medida a las anteriores, por su eficacia para obtener una decisión rápida cuando hay urgencia o un tercero altera de hecho el *statu quo*. No es acumulable a la indemnizatoria ni produce cosa juzgada sobre la calificación de culpa o dolo.

La reparación que persigue la acción indemnizatoria puede ser **en naturaleza** (*in natura*: reparar o reemplazar la cosa, cubrir los gastos médicos, publicar la sentencia que desmiente una difamación) o **en equivalente** (una suma de dinero). El derecho chileno no fija un orden de precedencia: la reparación en naturaleza es una

opción para el demandante, que solo procede si es materialmente posible y no resulta excesivamente gravosa para el demandado.

9.2. Legitimación activa: los titulares de la acción

La acción pertenece, como regla, a **quien sufre personalmente el daño**. Pero un mismo hecho puede afectar a varias personas, todas legitimadas. La doctrina distingue entre titulares por derecho propio y por derecho derivado.

9.2.1. Titulares por derecho propio

a) Lesionados directos — daño en las cosas. Si el daño recae sobre una cosa, son titulares tanto el **dueño** como el **poseedor**, y además quienes detentan otros derechos reales sobre ella (usufructuario, habitador, usuario), en la medida en que el daño perjudique sus respectivos derechos. El **mero tenedor**, en cambio, no tiene acción directa para reclamar el valor de la cosa: solo puede accionar en ausencia del dueño y, en tal caso, se entiende que lo hace a nombre de este y no a título personal (art. 2315). Con todo, sí está legitimado como titular de un *derecho personal* que se ejerce sobre la cosa —el arrendatario, por el perjuicio que experimenta su crédito—.

b) Lesionados directos — daño en las personas. Está legitimado quien sufre la lesión directa de un derecho o interés jurídicamente protegido, sea el daño patrimonial o moral.

c) Lesionados indirectos o víctimas por repercusión (rebote). Son quienes sufren un daño no en su persona o bienes, sino como consecuencia del daño padecido por la víctima directa —el dolor por la muerte de un ser querido, o la pérdida del sustento que aquella proporcionaba—. Aquí hay que distinguir:

- **Daño patrimonial por repercusión:** la doctrina y la jurisprudencia reconocen acción a todo aquel que recibía una *ayuda económica* de la víctima directa, **aun cuando no tuviera derecho a ella**, y que resulta privado de esa ayuda a consecuencia del accidente (el caso clásico del padre que pierde el auxilio pecuario de su hijo).
- **Daño moral por repercusión:** la regla general es más estricta: solo se concede acción en caso de *muerte* de la víctima directa y a condición de acreditar un **parentesco cercano**. Excepcionalmente se admite en caso de *lesiones*, cuando estas son de tal entidad que imponen de hecho una obligación de cuidado que altera la calidad de vida del pariente —quien debe hacerse cargo de la invalidez de la víctima—.

Ejemplo — Víctima directa y víctima por repercusión

Un trabajador muere atropellado por un camión que circulaba a exceso de velocidad. La **víctima directa** es el trabajador; su acción por el daño patrimonial ya devengado (gastos, lucro cesante hasta la muerte) se transmite a sus herederos. Pero su cónyuge y sus hijos son **víctimas por repercusión**: pueden demandar a título propio el daño patrimonial —la pérdida de la ayuda económica que el trabajador les proporcionaba— y el daño moral —el dolor por la muerte—. Estas acciones son *independientes* entre sí y no requieren la calidad de heredero.

9.2.2. Titulares por derecho derivado

Pueden ejercer la acción los **herederos** del legitimado por derecho propio, en virtud de la transmisibilidad de la acción. El Código lo dice expresamente para el daño en las cosas (art. **2315**: «puede pedir esta indemnización... el que es dueño o poseedor de la cosa... *o su heredero*»), pero se sostiene lo mismo respecto del daño a las personas. También puede ser titular el **cesionario**: el derecho a la indemnización *ya devengada* es cedible por acto entre vivos, incluso tratándose de daño moral, pues la indemnización tiene carácter patrimonial y ninguna norma prohíbe su transferencia.

9.2.3. Acción popular y acciones colectivas

Tratándose del **daño contingente** que por imprudencia o negligencia de alguien amenace a *personas indeterminadas*, la ley concede **acción popular** (art. **2333**); pero si la amenaza recae sobre personas determinadas, solo a ellas pertenece la acción. En nuestro ordenamiento no existe una acción de clase de alcance general (a diferencia de las *class actions* del *common law*); solo la Ley N.º 19.496 sobre protección del consumidor admite acciones en defensa del interés colectivo o difuso de los consumidores.

9.3. Legitimación pasiva: los obligados a responder

La acción se dirige contra todo aquel que responde del daño:

- **El autor del hecho ilícito** (art. **2316** inc. 1.º). La jurisprudencia entiende comprendido en el «autor» al *cómplice*, pero no al *encubridor*.
- **El responsable por el hecho ajeno** (arts. **2320** y **2322**), es decir, el *tercero civilmente responsable* —como el padre por el hecho del hijo menor que vive con él— (véase la Sección 6.3).
- **El que recibe provecho del dolo ajeno**, sin ser cómplice (art. **2316** inc. 2.º).
- **Los herederos** del responsable: la obligación de indemnizar es transmisible conforme a las reglas generales.

La hipótesis del **provecho del dolo ajeno** merece detenerse. Quien, sin haber participado en el delito, se beneficia de él, solo es obligado *hasta concurrencia del provecho* que reporta: su responsabilidad no es propiamente reparatoria, sino **restitutoria de un enriquecimiento sin causa**. La regla solo opera respecto del *dolo* (delitos), no de la culpa (cuasidelitos), y es paralela a la del art. **1458** inc. 2.º en materia de dolo incidental. Cosa distinta es quien *conoce* la existencia del dolo y es reticente en denunciarlo para aprovecharse de sus efectos: a este se le considera **autor** en razón de su reticencia, y responde por el total de los perjuicios.

No confundir — Cómplice, encubridor y el que se aprovecha del dolo

El **cómplice** responde como el autor, por el total. El **encubridor** —que interviene después de consumado el hecho— queda afecto a la obligación de indemnizar, pero solo *hasta el monto del provecho recibido* del dolo ajeno (art. **2316** inc. 2.º). Y quien se aprovecha del dolo siendo *reticente* para beneficiarse de él deja de ser un simple beneficiario: pasa a responder como autor por el total.

9.4. La solidaridad (art. 2317)

Cuando un mismo delito o cuasidelito ha sido cometido por **dos o más personas**, cada una de ellas responde **solidariamente** de todo el perjuicio (art. 2317 inc. 1.º). La víctima puede, así, cobrar el total a cualquiera de los responsables, sin necesidad de dividir su acción. Es una de las ventajas más relevantes del estatuto extracontractual frente al contractual, donde la regla general es la obligación conjunta.

Requisito. La solidaridad exige que dos o más personas hayan participado —como autores o cómplices— en la comisión de *un mismo* hecho ilícito. Si se trata de *hechos distintos* respecto de una misma víctima, no hay solidaridad: así, si una persona es atropellada por un vehículo y, habiendo quedado tendida en el camino, es atropellada luego por otro, hay dos cuasidelitos separados y cada conductor responde solo de su propio daño.

Excepciones legales (el propio art. 2317 las reserva): la *ruina de un edificio* que pertenece en común a varias personas, en que la indemnización se divide entre los copropietarios a prorrata de sus cuotas (art. 2323 inc. 2.º), y la *cosa que cae* de la parte superior de un edificio, en que —si no puede imputarse dolo o culpa a una persona determinada— el daño se divide por partes iguales entre todos los que habitan esa parte del edificio (art. 2328 inc. 1.º). Existen, además, casos especiales de solidaridad fuera del Código, como la del propietario del vehículo respecto del daño causado por quien lo conducía (legislación de tránsito).

Dato de grado — Obligación a la deuda vs. contribución a la deuda

Hay que distinguir dos planos. Frente a la **víctima** (obligación a la deuda), los coautores responden *solidariamente*: ella cobra el total a cualquiera. Pero una vez pagada la indemnización, surge el problema *interno* entre los coautores (contribución a la deuda): el que pagó puede repetir contra los demás. Como la ley no fija la forma de esa contribución, se aplica la regla de la solidaridad (art. 1522 inc. 2.º), de modo que cada uno soporta la parte que corresponda a su **grado de participación** en el hecho; ALESSANDRI, en cambio, sostiene que en silencio de la ley la contribución debe hacerse por partes iguales.

9.5. Tribunal competente y procedimiento

Si el hecho ilícito es a la vez civil y penal, la competencia para conocer de la acción indemnizatoria pertenece **indistintamente al juez civil o al penal, a elección de la víctima**. Si el hecho carece de sanción criminal (por ejemplo, un cuasidelito de daños), solo es competente el juez civil. Ante este, la acción se tramita conforme a las reglas del *juicio ordinario*; ante el juez del crimen, se sujeta a las reglas del Código Procesal Penal, pero no por ello deja de ser una acción civil.

Conviene tener presente una particularidad: según la jurisprudencia, en materia extracontractual **no se aplica el art. 173 del Código de Procedimiento Civil**, que permitiría reservar la discusión sobre la especie y el monto de los perjuicios para la ejecución del fallo o para un juicio diverso. En sede de delitos y cuasidelitos, todos los elementos —incluida la evaluación del daño— deben quedar establecidos en el mismo juicio. La **prueba** de cada uno de los elementos del hecho ilícito corresponde, por regla general, a la víctima, que puede valerse de todos los medios que la ley franquea.

9.6. Extinción de la acción y prescripción

La acción de responsabilidad se extingue, en general, por los **modos de extinguir las obligaciones**, pues su objeto es hacer valer una pretensión indemnizatoria. Conviene detenerse en tres:

- **Renuncia.** Producido el daño, la víctima puede renunciar a su reparación (art. **12**): la renuncia *posterior* al hecho es un acto de disposición que extingue la acción. Distinta es la autorización que la víctima da *con anterioridad* a la ocurrencia del daño, que no es renuncia sino una **causal de justificación** que opera como eximente (véase la Sección 5.3).
- **Transacción.** El Código la admite expresamente: «la transacción puede recaer sobre la acción civil que nace de un delito; pero sin perjuicio de la acción criminal» (art. **2449**). Las partes pueden componer libremente la indemnización ya devengada.
- **Prescripción.** Es el modo que plantea las cuestiones más debatidas, según se expone a continuación.

9.6.1. El plazo del art. 2332

La regla está en el art. **2332**: «Las acciones que concede este título por daño o dolo prescriben en **cuatro años** contados desde la **perpetración del acto**». Este plazo solo rige para la acción indemnizatoria que nace del delito o cuasidelito civil, y no para otras acciones que puedan corresponder a la víctima (como la reivindicatoria si fue objeto de robo), que se rigen por sus propias reglas. Existen, además, **plazos especiales**: un año para los daños por accidentes de aeronaves (Código Aeronáutico); cinco años para los defectos de construcción, contados desde la recepción final de la obra (Ley General de Urbanismo y Construcciones); y los plazos de la ruina de edificios, entre otros.

9.6.2. El gran debate: ¿desde cuándo se cuenta el plazo?

La expresión «perpetración del acto» es ambigua, y de ella nace una discusión de la mayor importancia práctica. **Lo normal es que la conducta del hechor y el daño coincidan en el tiempo** —el conductor atropella y la víctima se lesiona en el acto—; pero no siempre ocurre así, y es entonces cuando el problema se vuelve decisivo.

a) Tesis tradicional (ALESSANDRI y jurisprudencia clásica). El plazo corre desde la *perpetración del acto*, esto es, desde la acción u omisión imputable del hechor, **aunque el daño se ocasione después**. Su argumento de texto es que el Código habla de «perpetración del acto» y no «del daño». Su argumento de fondo, recogido por la Corte Suprema ya en 1922, es que contar el plazo desde el daño «importaría o hacer imprescriptible el hecho cometido... o fijarle una prescripción de mayor tiempo que el máximo» de la prescripción extraordinaria.

b) Tesis moderna (BARROS, ABELIUK y jurisprudencia reciente). La responsabilidad civil *no está completa si falta el daño*; mientras este no se produce, no nace la acción, porque el daño es un requisito de la indemnización. De ahí la observación de ABELIUK: la interpretación tradicional conduce al **absurdo de que la acción podría prescribir antes de nacer**. En consecuencia, el plazo solo debe empezar a correr **desde que el daño se manifiesta para la víctima**. Esta lectura es coherente con el *carácter sancionatorio* de la prescripción —que castiga a quien retarda indebidamente el ejercicio de sus derechos—: si la víctima no ha estado en condiciones de conocer el daño, no hay razón para que el plazo corra en su contra.

Atención — El daño que se manifiesta tardíamente

El nudo del problema aparece cuando el daño se revela **mucho después** de la conducta que lo origina. Tres ejemplos clásicos lo muestran:

- **El certificado erróneo del Conservador.** El Conservador otorga un certificado de gravámenes que omite una hipoteca; con su mérito, el acreedor presta dinero. El perjuicio solo se materializa años después, cuando al rematarse la propiedad no alcanza a pagarse por aparecer la hipoteca omitida. La tesis tradicional contaba el plazo desde la fecha del certificado (con lo que la acción podía estar prescrita al producirse el daño); la moderna, desde que el daño se manifiesta.
- **El fraude de descubrimiento tardío.** La víctima de un fraude sufre el menoscabo patrimonial efectivo, pero solo lo descubre tiempo después. Bajo la tesis moderna, el plazo no corre mientras no haya podido conocerlo.
- **El daño ambiental de evolución progresiva.** La Corte Suprema, en un caso de daños a una producción forestal que «sufrieron una evolución que culminó» en una fecha posterior, resolvió que el plazo de prescripción debía empezar a correr *desde esa fecha* y no desde la conducta inicial.

A ellos cabe añadir los daños corporales de aparición diferida (enfermedades de incubación lenta). Para evitar que la incertidumbre se eternice, BARROS propone como **límite prudente** el plazo de prescripción extraordinario (diez años): pasado ese término desde la conducta, la acción se extingue aunque el daño no se haya manifestado.

JURISPRUDENCIA — EL CÓMPUTO DEL PLAZO

Tesis tradicional. «El lapso de tiempo para prescribir estas acciones se cuenta, como lo determina el artículo 2332 del Código Civil, desde la perpetración del acto, o sea desde que se ha cometido el delito o cuasidelito, de donde nace la obligación que se demanda» (CS, 9 de enero de 1922).

Tesis moderna. «Tratándose de un cuasidelito civil, para que nazca el derecho es necesario que concurra el daño y, si este elemento falta, no ha nacido el derecho para demandar perjuicios» (CS, 19 de julio de 1995). En el mismo sentido, frente a daños forestales que evolucionaron en el tiempo, la Corte fijó el inicio del cómputo en la fecha en que el daño «culminó» (CS, 29 de diciembre de 1976).

9.6.3. Suspensión e interrupción

La **interrupción** de esta prescripción se rige por las reglas generales. En cuanto a la **suspensión**, hay discusión: para una parte de la doctrina (ALESSANDRI) se trataría de una prescripción de corto tiempo del art. 2524, que «corre contra toda clase de personas» y, por tanto, *no se suspende*. Para otra opinión —seguida por BARROS y por fallos recientes— la prescripción del art. 2332 no recae sobre «actos o contratos», sino sobre *hechos jurídicos* que dan lugar a responsabilidad, de

modo que no queda comprendida entre las del art. 2524 y se rige por las reglas generales: en consecuencia, **se suspende** a favor de las personas que enumera el art. **2509**. Por ser la suspensión una institución general de protección y deber interpretarse restrictivamente las excepciones, resulta preferible esta última posición.

Dato de grado — La prescripción del art. 2332 en tres golpes

(1) **Plazo:** cuatro años, contados «desde la perpetración del acto» (art. **2332**).
(2) **Dies a quo:** aquí está la pregunta de fondo. Tesis tradicional (ALESSANDRI): desde la conducta del hechor, aunque el daño venga después. Tesis moderna (BARROS, ABELIUK): desde que el *daño se manifiesta*, porque sin daño la acción aún no ha nacido —y no puede prescribir antes de nacer—; con el límite prudente de la prescripción extraordinaria (diez años). El criterio es clave en los *daños de manifestación tardía*. (3) **Suspensión:** discutida; la tendencia moderna admite que se suspende (art. **2509**), por no ser una prescripción de corto tiempo del art. 2524.

PAUSA — COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado la **Sección 9 — La acción de responsabilidad extracontractual** y, con ella, el manual completo. Entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta última sección para cerrar tu *check-in* de lectura. ¡Mucho éxito en el examen de grado!